

Haftpflichtkommentar

Vorbemerkungen zu Art. 41–61 OR

WILLI FISCHER, in:

Willi Fischer, Thierry Luterbacher

Haftpflichtkommentar - Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen

1. Auflage, 2016

Dike Verlag AG, ISBN 978-3-03751-685-0

[Seite 49] **Vorbemerkungen zu Art. 41–61 OR**

INHALTSVERZEICHNIS

	Note
I. Begriffliches	1
II. Charakteristik des ausservertraglichen Haftpflichtrechts	6
III. Ausservertragliches Haftpflichtrecht und seine Funktionen	9
A. Überblick	9
B. Schadensausgleich als Primärfunktion	10
C. Weitere Funktionen	12
IV. Ausservertragliches Haftpflichtrecht als Grundlage der Schadensabwälzung	16
A. Haftpflichtrecht als Ausnahme zum Grundsatz «casum sentit dominus»	16
B. Haftungszurechnungskriterien	17
C. Anknüpfungstatbestand	21
V. Haftungsarten und ihre Besonderheiten	22
A. Überblick	22
B. Persönliche Voraussetzungen beim Haftpflichtsubjekt als Anknüpfungstatbestand	25
C. Gesetzliche Anknüpfungstatbestände im Sinne «besonderer Beziehungen» bei Kausalhaftungen	26
1. Anknüpfungstatbestände	26
2. Ausnahmen	27
D. Unsorgfalt als Zusatzvoraussetzung gewisser (einfacher) milder Kausalhaftungen	28
1. Vermutete Unsorgfalt	28
2. Neue Qualifizierung der Haftungstatbestände als Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast qua Sorgfaltsbeweis	29
3. Kausalhaftungen trotz Sorgfaltsbeweis	30
VI. Allgemeine Voraussetzungen jeglicher ausservertraglichen Haftpflicht	34
A. Sachliche Voraussetzungen	34

1. Für alle Haftpflichtarten geltende sachliche Voraussetzungen	34
2. Pro memoria: Besondere sachliche Voraussetzungen gewisser Gefährdungshaftungen	37
B. Persönliche Voraussetzungen	39
1. Beim Haftpflichtigen	39
2. Beim Geschädigten (Subjekt der Haftpflichtförderung)	41
VII. Passiv- und Aktivlegitimation	42
A. Passivlegitimation: Subjekt der Haftpflicht	42
B. Aktivlegitimation (Anspruchsberechtigung)	44
1. Allgemeines	44
2. Direkter Schaden	45
3. Reflexschaden	51
3.1 Grundsatz	51
a) Keine Anspruchsberechtigung	51
b) Widerrechtlichkeit als einzig massgebendes Abgrenzungskriterium	52
c) Terminologische Konsequenz	53
3.2 Gesetzliche Ausnahmen: Anspruchsberechtigung	54
3.3 Weitere Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtentschädigung von Reflex- bzw. Drittschäden	56
VIII. Drittschadensproblematik bzw. Drittschadensliquidation im Besonderen	57
A. Prinzipielle Auswirkungsmöglichkeiten einer schädigenden Handlung auf Drittpersonen	57
1. Terminologisches als Vorbemerkung	57
2. Phänomenologie der Drittschadensproblematik und Drittschadensarten	58
B. Grundsatz der Nichtentschädigung von Drittschäden und seine Rechtfertigung	65
[Seite 50] C. Fehlender «sekundärer Rechtsgüterschutz» bei sog. «Drittschäden im engeren Sinn»	67
D. Versorgerschadenregelung als punktuelle positivrechtliche Anerkennung der Ersatzfähigkeit eines Drittschadens i.e.S.	70
E. Notwendigkeit einer Rechtsfortbildung mittels teleologischer Extension der Anspruchsgrundlagen	78
1. Bedeutung der Versorgerschadenregelung hinsichtlich der Ersatzfähigkeit der Drittschäden i.e.S.	78
2. Notwendigkeit einer Rechtsfortbildung	80

3. Rechtsfortbildung mittels teleologischer Extension der Anspruchsgrundlagen für Drittschäden i.e.S.

84

I. Begriffliches

Aufgabe des Schadenersatzrechtes ist, die Frage zu entscheiden, «ob und unter welchen Voraussetzungen der Geschädigte seinen Schaden abwälzen kann»,¹ wobei zwischen vertraglichem und ausservertraglichem Schadenersatzrecht unterschieden wird. **1**

In begrifflicher Hinsicht herrscht Vielfalt und damit auch zum Teil Verwirrung. Das vertragliche und ausservertragliche Schadenersatzrecht wird zum Teil auch gesamthaft als Haftpflichtrecht bezeichnet,² wobei hierzu neu auch die sog. «Vertrauenshaftung» gezählt wird.³ Andere wiederum beschränken den Begriff Haftpflichtrecht auf das gesamte Recht der ausservertraglichen Haftung, also sowohl auf die Verschuldens- als auch die Kausalhaftungen,⁴ und bezeichnen diese Materie zusätzlich als Deliktsrecht;⁵ gelegentlich wird unter Deliktsrecht aber lediglich die ausservertragliche Verschuldenshaftung subsumiert.⁶ **2**

Neuerdings wird das vertragliche und das ausservertragliche Haftpflichtrecht unter den Oberbegriff «Schadensrecht» zusammengefasst.⁷ Mit dem Begriff «Schadensrecht» werden aber auch lediglich jene Rechtssätze bezeichnet, «die den Inhalt der Schadenersatzpflicht bestimmen»,⁸ oder sogar nur die Schadenstheorien, d.h. den Schadensbegriff.⁹ **3**

[Seite 51] In der vorliegenden Kommentierung zu Art. 41–61 OR umfasst der Begriff Haftpflichtrecht im Sinne der herrschenden wissenschaftlichen Terminologie sämtliche ausservertraglichen Haftpflichttatbestände (Verschuldens-, Kausal- und Vertrauenshaftung), d.h. die «Summe derjenigen Normen, welche das zivilrechtliche Entstehenmüssen für ausservertragliche Schädigungen regeln»,¹⁰ also «das Entstehenmüssen für widerrechtlich zugefügte ausservertragliche Schädigung oder immaterielle Unbill». ¹¹ Der Begriff des Schadensrechts wird hier lediglich für das Recht des Schadensbegriffs, d.h. die Frage, worin der Schaden besteht (und den Inhalt des Schadenersatzes), verwendet.¹² **4**

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es im Vertragsrecht im Rahmen der sog. «positiven Vertragsverletzung» auch um den vertraglichen Schutz des Integritätsinteresses¹³ gehen kann, und dadurch Rechtsgüter auch hier schadenersatzrechtlich geschützt werden,¹⁴ sollte der singuläre Begriff «Haftpflichtrecht» vermieden und stattdessen a priori zwischen ausservertraglichem und vertraglichem Haftpflichtrecht unterschieden werden.¹⁵ **5**

II. Charakteristik des ausservertraglichen Haftpflichtrechts

Das aus dem freiheitlichen Denken des Liberalismus stammende Institut der Privatautonomie geht davon aus, «dass in einer freien Gesellschaft jedes Rechtssubjekt seinen Willen frei bilden, äussern und entsprechend handeln und für seine Handlungen grundsätzlich auch die volle Verantwortung tragen kann». ¹⁶ Das ausservertragliche Haftpflichtrecht «als Summe derjenigen Normen, welche das zivilrechtliche Entstehenmüssen für ausservertragliche Schädigungen regeln» (siehe vorne N 4), ist somit «das notwendige Komplement» und die «Kehrseite»¹⁷ der privatautonomen Handlungsfreiheit. Unter diesem Aspekt grenzt das ausservertragliche Haftpflichtrecht die einzelnen Rechtskreise der Rechtssubjekte voneinander ab und stellt mit der Möglichkeit, Schadenersatz zu fordern, ein ethisches Minimum sicher;¹⁸ dadurch schützt das ausservertragliche Haftpflichtrecht das Integritätsinteresse eines jeden Rechtssubjektes,¹⁹ d.h. dessen «Interesse an unverletzten Rechtsgütern». ²⁰ **6**

Kennzeichnend für das ausservertragliche Haftpflichtrecht ist auch, dass es jene Ansprüche regelt, die infolge einer **Rechtsgutverletzung aus einem zufälligen und** **7**

somit ungewollt [Seite 52] **ten Zusammentreffen Dritter** entstehen,²¹ d.h. ohne dass – wie bei der vertraglichen Haftung – vor der Verletzungshandlung eine Rechtsbeziehung zwischen den betroffenen Parteien bestehen musste und unabhängig davon, an welche Rechtsbeziehung die Ansprüche geknüpft werden.²² Solche vorbestehenden Rechtsverhältnisse hindern zwar die Entstehung von ausservertraglichen Ansprüchen nicht, sind aber nicht Voraussetzung,²³ können aber bei Erfüllung der für sie notwendigen Voraussetzungen zu Anspruchskonkurrenz führen.²⁴

Die ausservertragliche Haftung grenzt sich dadurch von der vertraglichen ab, als sie nicht auf der Verletzung einer vertraglich begründeten, sondern einer allgemeinen, gegenüber **jedermann geltenden Pflicht** beruht.²⁵ Führt die Verletzung solch allgemeiner Pflichten zur Verletzung des Integritätsinteresses eines Dritten, so korrigiert die ausservertragliche Haftung – sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind – als «Kehrseite» und als «notwendiges Komplement» zur privatautonomen Handlungsfreiheit (vgl. vorne N 6) den «Missbrauch» dieser Handlungsfreiheit zulasten eines Dritten. Das ausservertragliche Schadenersatzrecht grenzt somit die Rechtskreise der Einzelnen voneinander ab²⁶ und besitzt eine **Garantiefunktion**, indem es mittels Durchbrechung des Grundsatzes «casum sentit dominus» (vgl. hinten N 16) eine Veränderung der Rechtszuständigkeit bewirkt durch Anlastung des Schadens an den Schadensverursacher. Ohne diese Schadenanlastungsfunktion gäbe es auf der horizontalen Ebene zwischen gleichberechtigten Privaten keinen Rechtsgüterschutz, weil ohne Schadenanlastung das Integritätsinteresse des Geschädigten (= Interesse an der Erhaltung des unbeeinträchtigten Besitzstandes) dem Aktivitätsinteresse des Schädigers (= Interesse an möglicher Freiheit der Entfaltung) unterläge, selbst wenn das Verhalten des Schädigers als Missbrauch seiner Entfaltungsfreiheit erschiene.²⁷ **Das ausservertragliche Haftpflichtrecht erweist sich dadurch als Korrelat der letztlich grundrechtlich geschützten Privatautonomie,²⁸ indem es auf privatrechtlicher Ebene die in diesem Zusammenhang massgebenden Grundrechte mit ihren Einrichtungsgarantien gewährleistet mittels eines «sekundären Rechtsgüterschutzes»²⁹ bei ausservertraglicher Verletzung des Integritätsinteresses eines Dritten.** Dieser Erkenntnis betreffend der Strukturen und Wertungen ist bei der Auslegung des ausservertraglichen Haftpflichtrechts Rechnung zu tragen.³⁰

[Seite 53] III. Ausservertragliches Haftpflichtrecht und seine Funktionen

A. Überblick

So Unterschiedliches auch unter dem Begriff Haftpflichtrecht verstanden wird (vgl. vorne N 2 f.), so sehr herrscht Einigkeit darüber, dass das ausservertragliche Haftpflichtrecht die Rechtsgrundlage zur Verfügung stellt, um – sofern die Voraussetzungen erfüllt sind – allfällige Ansprüche gegen den Urheber eines Haftungsereignisses geltend zu machen. Inhalt einer derart verstandenen Obligation ist ein **Wiedergutmachungsanspruch**.³¹ Dieser Wiedergutmachungsanspruch kann in einem Anspruch auf Schadenersatz (Schadensausgleich) oder auf Genugtuung (Ersatz für immaterielle Unbill) bestehen.³² Neben dieser Wiedergutmachung mittels Ersatz kann eine sog. «unerlaubte Handlung» aber auch einen Anspruch «auf Beseitigung einer Störung oder auf Unterlassung weiterer Störungen auslösen».³³

B. Schadensausgleich als Primärfunktion

Im Rahmen der erwähnten Wiedergutmachungsansprüche stellt der Anspruch auf Schadenersatz und der damit verbundene Schadensausgleich die bedeutsamste Rechtsfolge dar. Das ausservertragliche Haftpflichtrecht ist nach h.L. und Rechtsprechung deshalb primär **Schadensausgleichsrecht** mit dem Ziel, dem

Geschädigten die finanziellen Nachteile eines vom Schädiger zu vertretenden Ereignisses auszugleichen.³⁴

Der Schadensausgleich findet seine Grenze jedoch an der Höhe des durch die unerlaubte Handlung entstandenen ökonomischen Nachteils, wodurch der Schadensausgleich durch **[Seite 54]** das **Bereicherungsverbot** begrenzt wird: Der Geschädigte soll aus dem Schadensereignis keine Vorteile ziehen.^{35, 36} **11**

C. Weitere Funktionen

Nach allgemeiner Auffassung zielt das Haftpflichtrecht bzw. das Schadenersatzrecht primär auf Schadensausgleich und erst in zweiter Linie auf Prävention ab.³⁷ **12**

Neuerdings betont die Lehre jedoch die stärkere Bedeutung der **Präventionsfunktion**, indem das Haftpflichtrecht «potenzielle Haftpflichtige» veranlasse, «Schäden zu vermeiden».³⁸ Die Prävention wird sogar als «eine der tragenden Ideen des Haftpflichtrechts» bezeichnet.³⁹ Danach soll das ausservertragliche Haftpflichtrecht «einen Anreiz schaffen, sich so zu verhalten, dass Dritte aufgrund eines Verhaltens nicht geschädigt werden».⁴⁰ **13**

Vor dem Hintergrund der Problematik, ob die Präventionsfunktion am ehesten der ausservertraglichen Verschuldenshaftung zukommt,⁴¹ und ob dabei zwischen der Verhinderung von Rechtsgutverletzungen (Schädigungen) und der Verhinderung ökonomischer Nachteile (Schäden) unterschieden werden soll,⁴² und zusätzlich nicht auszuschliessen ist, dass auch den «Kausalhaftungen – insbesondere den Gefährdungshaftungen – die Funktion einer (wirtschaftlich motivierten) Schadensprävention bzw. Gefahrenprophylaxe zukommen kann»,⁴³ gilt Folgendes zu bedenken: Prävention heisst Verhütung. Damit soll aber nicht nur bewirkt werden, dass potentielle Schädiger veranlasst werden, ihre individuelle Sorgfalt zu steigern, um nicht die finanziellen Folgen einer Schädigung tragen zu müssen.⁴⁴ Primäres Anliegen einer Rechtsordnung muss sein, Rechtsverletzungen zu verhindern, statt nur für einen nachträglichen Ausgleich zu sorgen. Es geht deshalb im Rahmen des ausservertraglichen Haftpflichtrechts darum, «das Verhalten der Bürger durch Setzung entsprechender Anreize ganz allgemein so zu steuern, dass Schadenereignisse verhütet werden, die zu verhüten wegen des damit verbundenen Gewinns an gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrt sinnvoll ist».⁴⁵ Das Schadenersatzrecht/Haftpflichtrecht besitzt deshalb zweifellos eine **objektive Präventivfunktion**, die unabhängig von der Haftungsart vor allem bei rational gesteuerten **[Seite 55]** Wirtschaftseinheiten und anderen Organisationen bedeutungsvoll ist.^{46, 47} «Der Gedanke der Prävention, d.h. der Abschreckung vor dem Rechts- oder Vertragsbruch, spielt» somit «neben dem Gedanken, dass jeder für die Folgen seines Tuns einzustehen habe, für die Begründung der Ersatzpflicht [...] aus «unerlaubter Handlung» [...] eine bedeutende Rolle».⁴⁸ Insb. nicht zuletzt auch deshalb, weil die Rechtsordnung als Ganzes ein Interesse an Vorbeugung haben muss.⁴⁹ **14**

Überwunden ist heute die Auffassung, wonach der Verschuldenshaftung **pönale Funktion** zukommt.⁵⁰ Die Zusprechung von punitive damages (Strafschadenersatz) entsprechend dem anglo-amerikanischen Rechtskreis ist deshalb unzulässig.⁵¹ **Art. 43 OR** gibt zwar die Möglichkeit der Reduktion des Schadenersatzes bei geringem Verschulden des Schädigers (Proportionalität zwischen Schuld und Ersatzpflicht), was für den «Einbezug strafrechtlicher Gesichtspunkte ins Haftpflichtrecht» sprechen könnte⁵² und im Gegensatz zum Ausgleichsprinzip des Haftpflichtrechts steht.⁵³ Jedoch, diese Proportionalität zwischen Schuld und Ersatzpflicht wird durch die «Objektivierung des Verschuldensbegriffs [...] sowie durch die in der Praxis restriktiv gehandhabte und nur bei leichtem Verschulden zur Anwendung gelangende Reduktion [...] beträchtlich relativiert».⁵⁴ Zudem ist immer nur eine Ermässigung der Ersatzpflicht möglich, zu mehr als zum errechneten **15**

Schadensbetrag kann die Schadenersatzleistung auch bei grobem Verschulden des Haftpflichtigen nicht gehen.

IV. Ausserververtragliches Haftpflichtrecht als Grundlage der Schadensabwälzung

A. Haftpflichtrecht als Ausnahme zum Grundsatz «casum sentit dominus»

Das schweizerische Haftpflichtrecht kennt keine Regel, wonach für jeden Schaden ein Ersatzpflichtiger zu finden ist.⁵⁵ Es basiert auf dem gemeinrechtlichen Grundsatz **«casum sen [Seite 56] tit dominus»**, wonach der Geschädigte seinen Schaden selber tragen muss, ausser wenn der Schaden ausnahmsweise auf einen Ersatzpflichtigen abgewälzt werden kann.⁵⁶ Für diese Schadensabwälzung stellt das Haftpflichtrecht die **Rechtsgrundlage** zur Verfügung⁵⁷ und ist insofern das «Recht der Ausnahmen» dieses Grundsatzes.⁵⁸ Als Folge der Tendenz, die Haftungsgrundlagen aus sozialen Gründen immer weiter auszudehnen⁵⁹ sowie als Folge der starken (Sozial-)Versicherungsdurchdringung sämtlicher Lebenssachverhalte, ist dieser Grundsatz stark in den Hintergrund gedrängt worden.⁶⁰ Und trotzdem bildet dieser Grundsatz «noch den Ausgangspunkt aller Überlegungen»⁶¹ und drückt die Selbstverständlichkeit aus, «dass jedermann sein «allgemeines Lebensrisiko» selbst zu tragen hat und es nicht einfach auf andere Privatrechtssubjekte abwälzen kann».⁶²

16

B. Haftungszurechnungskriterien

Die Ausnahme vom Grundsatz «casum sentit dominus», also das ausserververtragliche Haftpflichtrecht mit seiner primären Schadensausgleichfunktion (vgl. vorne N 10), schafft zwar die Rechtsgrundlage für die Schadensabwälzung, beantwortet aber nicht die Frage, warum der Schaden vom Verursacher gedeckt werden muss.⁶³ Aus der Sicht des Geschädigten ist es nämlich gleichgültig, woher die Kompensation kommt.

17

Die Begründung, warum «die Verlagerung des Schadens des Geschädigten auf den Verursacher» stattfinden soll, kann deshalb nicht aus dem Kompensationsgedanken abgeleitet werden,⁶⁴ sondern einzig aus der Idee, «dass niemand einem anderen **unberechtigterweise** Schaden zufügen darf («neminem laedere»), bzw. dass niemand eine unberechtigterweise erlittene Schädigung zu dulden hat»,⁶⁵ was immer dann der Fall ist, wenn für eine Schadensabwälzung und damit Haftbarmachung eine sog. «innere Rechtfertigung» besteht.⁶⁶

18

Die sog. «innere Rechtfertigung», d.h. die Motivierung für die Schadensabwälzung, stellt das für die in Frage stehende Haftungsart geltende Haftungsprinzip bzw. Zurechnungskriterium dar. Für die **Verschuldenshaftung** ist dies das Verschulden «als tadelnswert zu qualifizierendes Verhalten», während es (vor allem) bei den sog. **«Kausalhaftungen»** «kein ein [Seite 57] heitliches Haftungsprinzip», also keine einheitliche «innere Rechtfertigung» für die Schadensabwälzung gibt.^{67, 68}

19

Die **einfachen** (gewöhnlichen) **Kausalhaftungen** knüpfen zur Haftungs begründung im Sinne einer Haftungszurechnung an «irgendwie geartete Ordnungswidrigkeiten oder Unregelmässigkeiten» an (zu den einzelnen Zurechnungskriterien bei den Kausalhaftungen siehe hinten N 28).⁶⁹ Demgegenüber bildet bei den **Gefährdungshaftungen** eine **besondere Gefahr** den Anknüpfungstatbestand (vgl. hierzu hinten N 26) und Haftungszurechnungskriterium ist die Überlegung, dass derjenige das Haftungsrisiko tragen soll, der den wirtschaftlichen Nutzen aus dem selbst geschaffenen besonderen Zustand zieht.⁷⁰

20

C. Anknüpfungstatbestand

Im Unterschied zum Haftungszurechnungskriterium, welches die innere Rechtfertigung für eine Haftung bildet (vgl. vorne N 17 ff.), beschreibt der sog. **«Anknüpfungstatbestand»** den Lebensvorgang (z.B. menschliches Verhalten) bzw.

21

das Ereignis (z.B. Betrieb einer gefährlichen Anlage), an das die Schadensabwälzung anknüpft.⁷¹

V. Haftungsarten und ihre Besonderheiten

A. Überblick

Im ausservertraglichen Haftpflichtrecht werden traditionellerweise zwei Haftungsarten unterschieden: die **Verschuldenshaftung** nach Art. 41 OR sowie die **verschuldensunabhängigen Kausalhaftungen**.⁷² Aufgrund der zusätzlichen Unterteilung der Kausalhaftungen in «einfache Kausalhaftungen» und «Gefährdungshaftungen» wird auch von einer **Haftungstrilogie** gesprochen.⁷³ Neuerdings wird sogar von vier Haftungsarten gesprochen, da die «kausalen Freistellungshaftungen des öffentlichen Rechts» zu einer neuen Unterart der Kausalhaftungen zusammengefasst werden.⁷⁴

[Seite 58] Ein Teil der Lehre unterscheidet im Rahmen der einfachen (gewöhnlichen) Kausalhaftungen zusätzlich zwischen **milden** und **scharfen** Kausalhaftungen entsprechend dem Abgrenzungskriterium des sog. «Sorgfaltsbeweises», der bei den milden (einfachen) Kausalhaftungen⁷⁵ zur Verfügung steht.⁷⁶ Andere wiederum setzen die Grenzziehung zwischen «milder» und «scharfer» Kausalhaftung zwischen gewöhnlichen Kausalhaftungen und Gefährdungshaftungen.⁷⁷

Als Ausnahme vom Grundsatz der Verschuldenshaftung bedarf jede Kausalhaftung einer besonderen gesetzlichen Grundlage. Die Gefährdungshaftungen sind ausschliesslich ausserhalb des OR in Spezialgesetzen geregelt.

B. Persönliche Voraussetzungen beim Haftpflichtsubjekt als Anknüpfungstatbestand

Während bei der Verschuldenshaftung das **persönliche Verschulden** i.S. eines als «tadelnswert zu qualifizierenden Verhaltens» des Haftpflichtigen (vgl. vorne N 19) nicht nur Haftungszurechnungsgrund und damit Rechtsgrund der Schadensabwälzung⁷⁸ bildet, sondern auch als **Anknüpfungstatbestand** (menschliches Verhalten, das in einer vorwerfbaren Pflichtverletzung besteht) dient (vgl. vorne N 21), setzen die sog. «**Kausalhaftungen**» (sowohl die einfachen [milden und scharfen/strengen] als auch die Gefährdungshaftungen) kein persönliches Verschulden des Haftpflichtigen voraus. Persönliche Voraussetzung beim Subjekt der Haftpflicht einer Kausalhaftung und damit Anknüpfungstatbestand bildet (anstelle des Verschuldens) «**eine besondere Beziehung des Haftpflichtigen zum haftungsbegründenden Tatbestand**», welcher Schadensursache sein muss.⁷⁹

[Seite 59] C. Gesetzliche Anknüpfungstatbestände im Sinne «besonderer Beziehungen» bei Kausalhaftungen

1. Anknüpfungstatbestände

Die bei den einfachen (milden und scharfen/strengen) Kausalhaftungen als auch bei den Gefährdungshaftungen als persönliche Voraussetzung an die Stelle des Verschuldens tretende «besondere Beziehung des Haftpflichtigen zum haftungsbegründenden Tatbestand» (vgl. vorne N 25), an die das Gesetz die Haftung knüpft, ist ganz unterschiedlicher Art, nämlich:⁸⁰

- **Halterverhältnis**: vgl. Art. 58 SVG (Motorfahrzeughaftpflichtversicherung),⁸¹ Art. 64 Abs. 1 LFG; Art. 56 OR (Tierhalter);⁸²
- **Innehaben eines Betriebes**: vgl. Art. 40b EBG (Eisenbahn);⁸³ Art. 30a BSG (Binnenschifffahrt);⁸⁴ Art. 33 RLG; Art. 27 Abs. 1 EleG (elektrische Anlage);⁸⁵ Art. 3 Abs. 1–3 KHG (Atomanlage); Art. 59a USG; Art. 27 SprstG;
- **Eigentum**: vgl. Art. 58 OR (Werkeigentum);⁸⁶ Art. 679 ZGB (Grundstückseigentum);⁸⁷ Art. 3 Abs. 4 KHG (Atomanlage);

- **Überordnungsverhältnis:** vgl. **Art. 55 OR** (Geschäftsherrenhaftpflicht);⁸⁸ **Art. 333 ZGB** (Familienhauptaftung);⁸⁹
- **Hersteller:** vgl. **Art. 1 PrHG** (Produktehaftpflicht).

2. Ausnahmen

Ausnahmen vom Grundsatz, wonach bei Kausalhaftungen eine «besondere Beziehung des Haftpflichtigen zum haftungsbegründenden Tatbestand» notwendig ist, sind u.a.: 27

- **Art. 54 OR** (Billigkeitshaftung urteilsunfähiger Personen);
- **Art. 15 JSG** (Haftpflicht des Jägers);
- **Art. 137 MG** (Haftung nach dem Militärgesetz);
- **Art. 30 GTG** (Haftung nach Gentechnikgesetz).

[Seite 60] Diese Haftungen setzen wie die Verschuldenshaftung ein persönliches Handeln des Haftpflichtigen voraus⁹⁰ bzw. knüpfen an einer gefährlichen Tätigkeit an.⁹¹

D. Unsorgfalt als Zusatzvoraussetzung gewisser (einfacher) milder Kausalhaftungen

1. Vermutete Unsorgfalt

Bei den einfachen (gewöhnlichen) Kausalhaftungen⁹² setzen einzelne der sog. «milden Kausalhaftungen» – **Art. 55 OR** (Geschäftsherrenhaftung), **Art. 56 OR** (Tierhalterhaftung), **Art. 59a OR** (Haftung für Signaturschlüssel), **Art. 333 ZGB** (Familienhauptaftung) – zur Schadensabwälzung anstelle des Verschuldens nicht nur eine «besondere Beziehung des Haftpflichtigen zum haftungsbegründenden Tatbestand» als Anknüpfungstatbestand, sondern auch eine **Unsorgfalt** voraus, die bei Verwirklichung des haftungsbegründenden Tatbestandes gesetzlich vermutet wird.⁹³ Der Haftpflichtige kann sich jedoch befreien, indem er den sog. «Sorgfaltsbeweis» oder «Exkulpationsbeweis» erbringt, d.h., indem er nachweist, dass er alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt aufgewendet hat. 28

2. Neue Qualifizierung der Haftungstatbestände als Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast qua Sorgfaltsbeweis

Wegen dieser Befreiungsmöglichkeit mittels des Sorgfaltsbeweises wird heute z.T. vertreten, es handle sich hier nicht um sog. «einfache Kausalhaftungen», sondern um Verschuldenshaftungen mit umgekehrter Beweislast bzw. um eingeschränkte Verschuldenshaftungen.⁹⁴ Diese Qualifikation soll sogar für jene Haftungen gelten, «die keinen Entlastungsbeweis vorsehen, wie **Art. 58 OR**, **Art. 679 ZGB** oder **Art. 273 SchKG**», da die Haftung auch in diesen Fällen «an eine gewisse Sorgfaltsverletzung» anknüpfe, «sei es in [Seite 61] Form der Mangelhaftigkeit des Werkes, sei es in Überschreitung des Grundeigentumsrechts, sei es durch eine Sorgfaltsverletzung [...]».^{95, 96} 29

3. Kausalhaftungen trotz Sorgfaltsbeweis

Vorstehend wiedergegebene dogmatische Neueinteilung der sog. «einfachen Kausalhaftungen» überzeugt nicht. Eine Verwandtschaft der einfachen Kausalhaftungen mit der Verschuldenshaftung lässt sich zwar nicht leugnen, insb. vor dem Hintergrund der Entstehungsgeschichte von Art. 55 und 56 OR sowie **Art. 333 ZGB**.⁹⁷ Die Befürworter einer solchen Neuqualifikation berücksichtigen jedoch zu wenig, dass bspw. der in den Kausalhaftungen erwähnte Sorgfaltsbeweis nicht identisch ist mit dem Verschulden bzw. dem Exkulpationsbeweis, wie er bei der Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast vorkommen müsste.⁹⁸ Da die gesetzlichen Anforderungen an den Sorgfaltsbeweis strenger sind als beim Beweis der Schuldlosigkeit (= Exkulpationsbeweis), muss z.B. der Geschäftsherr nicht nur 30

beweisen, «dass er mit dem von einem objektivierten Durchschnittstyp erwarteten durchschnittlichen Mass an schadensvermeidender Sorgfalt vorgegangen ist», was den Massstab der Fahrlässigkeit darstellt (vgl. **Art. 41 OR** N 157 und 165 ff.), sondern «ihm obliegt [...] der Nachweis, dass er **alle** nach den konkreten Umständen **objektiv gebotene Sorgfalt** angewendet hat».⁹⁹ Vor diesem Hintergrund haftet er selbst dann, wenn ihm auch nur eine minimale Pflichtverletzung vorgeworfen werden kann, die noch kein Verschulden darstellt, was bei einer Fahrlässigkeit ja gerade ein Verhalten verlangt, das eine gesetzlich geforderte Durchschnittssorgfalt nicht erreicht.¹⁰⁰

Die Befürworter einer Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast übersehen auch, dass wegen der gänzlichen Objektivierung des geforderten Verhaltens Urteilsfähigkeit des Haftpflichtigen – als subjektive Seite des Verschuldens – nicht Haftungsvoraussetzung ist, **[Seite 62]** er haftet deshalb auch, wenn er im Zeitpunkt der schädigenden Handlung urteilsunfähig war.¹⁰¹ **31**

Zudem haftet bei diesen Tatbeständen der präsumtiv Haftpflichtige «für das Verhalten von Hilfspersonen»,¹⁰² und zwar auch wenn im Rahmen von **Art. 56 OR** die Sorgfaltsverletzung durch eine Hilfsperson begangen wurde,¹⁰³ oder wenn im Rahmen von **Art. 58 OR** der Werkmangel auf ein Drittverschulden zurückzuführen ist¹⁰⁴ oder einzig auf Zufall beruht.¹⁰⁵ **32**

Vor dem Hintergrund all dieser Argumente ist **an der traditionellen Einteilung als sog. «einfache/milde Kausalhaftung» festzuhalten**. Der Begriff «Kausalhaftung» stellt «auch in rechtsfolgerechtlicher Hinsicht eine sinnvolle Differenzierung gegenüber der Verschuldenshaftung dar».¹⁰⁶ **33**

VI. Allgemeine Voraussetzungen jeglicher ausservertraglichen Haftpflicht

A. Sachliche Voraussetzungen

1. Für alle Haftpflichtarten geltende sachliche Voraussetzungen

Für sämtliche ausservertraglichen Haftungen müssen unabhängig von den Haftungsarten (vgl. N 22 ff.) **kumulativ**¹⁰⁷ folgende Voraussetzungen erfüllt sein: **34**

- Existenz eines **Vermögensschadens** (vgl. **Art. 41 OR** N 15 ff.) oder einer **immateriellen Unbill** (vgl. **Art. 47 OR** N 1 und 34),
- Vorliegen einer **Widerrechtlichkeit** (vgl. **Art. 41 OR** N 58 ff.),
- adäquater (und auch natürlicher) **Kausalzusammenhang** (vgl. **Art. 41 OR** N 130 ff.) zwischen Schadensursache und Vermögensschaden.

Die Verschuldenshaftung, die einfachen (milden und scharfen/strengen) Kausalhaftungen und die Gefährdungshaftungen setzen folglich voraus, dass kumulativ ein Vermögensscha **[Seite 63]** den (oder eine immaterielle Unbill) durch eine widerrechtliche Handlung (natürlich und) adäquat kausal verursacht wurde.¹⁰⁸ **35**
Zu beachten gilt dabei, dass bei der Verschuldenshaftung der Haftpflichtige selbst, hingegen bei der Kausalhaftung der gesetzlich vorgesehene Anknüpfungstatbestand (vgl. vorne N 25 f.), den Schaden (und/oder die immaterielle Unbill) verursacht haben muss.¹⁰⁹

Zur Detailbehandlung der drei sachlichen, für alle Haftpflichtarten geltenden Voraussetzungen vgl. die Kommentierung zu **Art. 41 OR**. **36**

2. Pro memoria: Besondere sachliche Voraussetzungen gewisser Gefährdungshaftungen

In einzelnen Gefährdungshaftungstatbeständen wird neben den Anknüpfungstatbeständen (vgl. vorne N 25 f.) als besondere sachliche Voraussetzung **37**

die Verwirklichung der Betriebsgefahr (Art. 40b EBG, Art. 27 EleG, Art. 58 Abs. 2 SVG) bzw. eines Unfalls (Art. 27 Abs. 2 EleG, Art. 58 Abs. 2 SVG) verlangt.

Die Voraussetzung der «verwirklichten Betriebsgefahr» soll jene Schadensfälle ausschliessen, die zwar mit dem Betrieb zusammenhängen, aber nichts mit der besonderen Betriebsgefahr zu tun haben. Dieselbe Funktion hat das Erfordernis des Unfalls. In beiden Fällen fehlt jedoch der adäquate Kausalzusammenhang, wenn ein Schaden nicht Folge der durch die Gefährdungshaftung anvisierten (Betriebs-)Gefahr bzw. nicht Folge eines Unfalls ist (z.B. Erkältung wegen ungenügender Heizung, bzw. Krankheit, die nicht Unfallfolge ist). Denn die fraglichen Gefährdungshaftungen sind ja ohnehin nur auf jene Fälle anwendbar, in denen sich die Betriebsgefahr bzw. der Unfall realisiert. Vor diesem Hintergrund ist die Verwirklichung der Betriebsgefahr bzw. das Erfordernis eines Unfalles als besondere sachliche Haftungsvoraussetzung obsolet.¹¹⁰ 38

B. Persönliche Voraussetzungen

1. Beim Haftpflichtigen

Neben den sachlichen Voraussetzungen einer jeglichen Haftpflicht (vgl. N 34) verlangt die für eine Haftpflicht notwendige Abwälzung des Schadens des Geschädigten auf den Verursacher eine innere Rechtfertigung, d.h. ein Zurechnungskriterium (vgl. vorne N 17 ff., insb. N 19 f.). Beim Haftpflichtigen ist dies im Rahmen der Verschuldenshaftung das **persönliche Verschulden**, bei den Kausalhaftungen die «**besondere Beziehung des Haftpflichtigen zum haftungsbegründenden Tatbestand**» (vgl. N 25). 39

[Seite 64] Für die Darstellung dieser persönlichen Voraussetzungen vgl. die Kommentierung der einschlägigen Normen (Art. 41, 55, 56 und 58 OR sowie Spezialgesetze). 40

2. Beim Geschädigten (Subjekt der Haftpflichtforderung)

Die persönliche Voraussetzung beim Geschädigten bzw. beim Subjekt der Haftpflichtforderung ist identisch mit der Frage nach seiner Aktivlegitimation. Vgl. hierzu hinten N 44 ff. 41

VII. Passiv- und Aktivlegitimation

A. Passivlegitimation: Subjekt der Haftpflicht

Haftpflichtig, d.h. passivlegitimiert ist der Urheber einer unerlaubten Handlung. Dies kann sowohl eine natürliche (Art. 11 ZGB) als auch eine juristische Person (Art. 52 ZGB) sein. Für die juristische Person trifft dies jedoch nur zu, wenn die handelnde Person als deren Organ i.S.v. Art. 55 Abs. 2 ZGB handelt.¹¹¹ In diesem Falle kann die juristische Person solidarisch neben der natürlichen Person haften.¹¹² Fehlt die Organeigenschaft, kann eine Haftung aus Art. 55 OR gegeben sein (zur Abgrenzung zwischen Art. 55 OR und Art. 55 ZGB vgl. Art. 55 OR N 7). Zur Kollektiv- und Kommanditgesellschaft vgl. Art. 567 Abs. 3 OR.¹¹³ Stirbt der präsumtiv Haftpflichtige, so treten seine Erben in seine Stellung als Haftpflichtsubjekt ein, sofern die Erbschaft nicht ausgeschlagen wird.¹¹⁴ 42

Für die **Organstellung** kommt es nicht auf die Bezeichnung der natürlichen Person an, sondern auf ihre tatsächliche Stellung, d.h. die Möglichkeit, die Willensbildung der juristischen Person zu beeinflussen. Es genügt nicht, wenn ein Mitarbeiter in einem stark eingeschränkten Geschäftsbereich die ihm übertragene Tätigkeit selbständig ausführt.¹¹⁵ Ob Organ (Art. 55 ZGB) oder blosser Hilfsperson (Art. 55, 101 OR) ist bedeutsam für die Stellung im Regress (vgl. Art. 51 OR). 43

[Seite 65] B. Aktivlegitimation (Anspruchsberechtigung)

1. Allgemeines

Bei der Frage der Aktivlegitimation bzw. der Anspruchsberechtigung geht es um die rechtliche Stellung eines Vermögensgeschädigten.¹¹⁶ Denn ein und dasselbe Schadensereignis kann sich vermögensmässig bei verschiedenen Personen auswirken.¹¹⁷ 44

2. Direkter Schaden

Anspruchsberechtigt und damit aktivlegitimiert nach den Grundsätzen des ausservertraglichen Haftpflichtrechts ist jeder, der einen sog. «**direkten Schaden**», d.h. einen **Eigenschaden**,¹¹⁸ erlitten hat.¹¹⁹ Rechtsfähigkeit reicht. Daher kann auch das ungeborene Kind (nasciturus) unter Vorbehalt seiner lebenden Geburt Haftpflichtansprüche stellen (**Art. 31 Abs. 2 ZGB**).¹²⁰ 45

Die Frage der Anspruchsberechtigung ist im Rahmen von **Art. 41 ff. OR** eine Frage der **Widerrechtlichkeit** (vgl. hierzu **Art. 41 OR** N 58 ff.). Nur wer selbst aufgrund einer widerrechtlichen Handlung einen Vermögensschaden (vgl. hierzu **Art. 41 OR** N 15 ff.) erleidet, ist ein sog. «**Direktgeschädigter**» und – bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen – ersatzberechtigt.¹²¹ «Die Frage der subjektiven Anspruchsberechtigung deckt sich damit mit der Frage nach der *Widerrechtlichkeit* einer schädigenden Handlung.»¹²² 46

Das Bundesgericht hielt diesbezüglich – ohne direktes Abstellen auf die Voraussetzung der Widerrechtlichkeit – wiederholt fest, dass aus unerlaubter Handlung «ein Schadenersatzanspruch in der Regel nur für den, der hievon unmittelbar betroffen wird, nicht auch für Dritte, welche durch eine Reflexwirkung des Deliktes mittelbar benachteiligt werden», entstehe.¹²³ Die durch das Delikt mittelbar Geschädigten werden als Reflex- oder Drittschädigte bezeichnet. 47

Schockschäden: Ob ein direkter Schaden/Eigenschaden vorliegt, ist entgegen der vorstehenden Formulierung des BGER, in der es auf den Mechanismus abstellt (vgl. N 47), unab **[Seite 66]** hängig von der viel beschworenen Reflexwirkung und unabhängig von der Länge der Kausalkette. Entscheidend ist einzig, ob gegenüber dem Vermögensgeschädigten selbst widerrechtlich gehandelt wurde. Aus diesem Grunde zählen die **Schockschäden Dritter** zu den **direkten Schäden**, wurde doch durch Verletzung ihrer Persönlichkeit auch ihnen gegenüber (direkt) widerrechtlich gehandelt.^{124, 125, 126} 48

Im Gegensatz zu **BGE 112 II 118**, E. 8 geht wohl auch **BGE 138 III 276**, E. 2 ff. wieder von einem Reflexschaden aus, indem in E. 4 der Schockschaden wieder als ein «reflektorischer Schockschaden» qualifiziert wird. JAUN¹²⁷ zieht daraus folgende Konsequenz: «Auszugehen ist demnach wie bei der Angehörigengenußtuung und dem Versorgerschaden von einem durch den Tod oder die Verletzung des Angehörigen reflektorisch erzeugten Recht des Schockgeschädigten mit der Folge, dass in Bezug auf die übrigen Voraussetzungen des Haftpflichtanspruchs auf die Rechtslage des Unfallopfers gegenüber dem Haftpflichtigen abzustellen ist. Dieser kann sich somit im Rahmen von **Art. 44 OR** auch auf Umstände berufen, die der Verstorbene oder Verletzte zu vertreten hat, namentlich auf dessen Selbstverschulden oder eine Mitverantwortung aus einer Betriebsgefahr.» Abgesehen davon, dass **BGE 138 III 276**, E. 2 ff. gegenüber dem Grundsatzurteil für Schockschäden Dritter¹²⁸ einen Rückschritt darstellt, verkennen sowohl das BGER als auch JAUN die phänomenologischen Unterschiede: Im Rahmen des Versorgerschadens geht es um den ausnahmsweisen Ersatz eines Drittschadens, bei dem alle anspruchsbegründenden Voraussetzungen ausser derjenigen des Schadens in der Person des Getöteten erfüllt sein müssen mit der Konsequenz, dass die Versorgten ihren Anspruch aus der gegen den Versorger begangenen Handlung herleiten (vgl. hinten N 70). Deshalb müssen die Versorgten sämtliche ersatzmindernden Umstände auch gegen sich gelten lassen, folglich auch ein Selbstverschulden des Getöteten. Beim Schockschaden eines Dritten sind dem 49

Dritten gegenüber jedoch alle Voraussetzungen des Tatbestandes von **Art. 41 Abs. 1 OR** selbst erfüllt. Handelt es sich hier aber wie gezeigt um einen Anwendungsfall von **Art. 41 Abs. 1 OR**, so ist kein Platz für eine Anrechnung eines allfälligen Verschuldens des Getöteten, geht es hier doch nicht um sog. «Drittschadensersatz» wie bei **Art. 45 Abs. 3 OR** (vgl. hierzu hinten N 70 ff.).¹²⁹

[Seite 67] Stromkabelbruchfälle: Dasselbe, d.h. Vorliegen von direkten Schäden, gilt in den sog. «Stromkabelbruchfällen»¹³⁰ für jene geschädigten Drittpersonen, die wegen des Stromkabelbruchs einen Vermögensschaden ohne eigene Verletzung eines absoluten Rechts¹³¹ erleiden, der Schaden aber als rechtlich relevant erklärt wird, indem die Widerrechtlichkeit der Schädigung über den (angeblichen) Schutzzweck von **Art. 239 StGB** (Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen) hergestellt wurde (Anwendung der sog. «Schutzzwecktheorie», vgl. hierzu **Art. 41 OR** N 62 ff.).¹³²

3. Reflexschaden

3.1 Grundsatz

a) Keine Anspruchsberechtigung

Unmittelbar mit dem Begriff der Widerrechtlichkeit verbunden ist folglich auch die grundsätzliche Verneinung der Aktivlegitimation und damit die grundsätzliche Verneinung einer Haftung für sog. **«indirekten Schaden» oder «Reflexschaden»**. Hier handelt es sich nach h.L. um Vermögenseinbussen, die einer Drittperson als Folge einer Schädigung einer anderen, nämlich der sog. «direktgeschädigten Person» entstehen; gegenüber diesen Drittpersonen, die zwar einen Vermögensschaden erleiden, wird aber nicht auch widerrechtlich gehandelt. Ihrem Schaden fehlt die eigene Widerrechtlichkeit. Beispielhaft lässt sich hier etwa der Fall des Solisten anführen, der von einem Autofahrer angefahren wird und aufgrund seiner Verletzung nicht am vereinbarten Konzert auftreten kann. Neben dem Solisten (Schaden bestehend aus Heilungskosten plus Lohn- bzw. Honorarausfall) erleidet auch der Konzertveranstalter einen eigenen (sog. «indirekten»/«reflektorisch erzeugten») Vermögensschaden (z.B. Erlösausfall), der jedoch mangels eigener Widerrechtlichkeit nicht ersatzfähig ist.¹³³

b) Widerrechtlichkeit als einzig massgebendes Abgrenzungskriterium

Bei der Abgrenzung des direkten (= ersatzfähigen) vom indirekten (= nicht ersatzfähigen) Vermögensschaden steht heute aufgrund des Dargelegten nicht mehr die Person des Geschädigten bzw. der Entstehungsmechanismus eines Schadens im Vordergrund. Vielmehr geht es einzig um die Frage, ob der verursachte Schaden unabhängig von der Stellung der geschädigten Person in der Kausalkette und damit unabhängig davon, ob der Schaden direkt oder über eine «Zwischenperson» (indirekt) **widerrechtlich** zugefügt wurde. Letztlich geht es somit um die hinter der Widerrechtlichkeit stehende Frage, «wer durch die vom Haft **[Seite 68]** pflichtigen verletzte Norm geschützt ist, also um den «Schutzzweck der verletzten Pflicht».¹³⁴ Dies zeigt sich exemplarisch in den Stromkabelbruchfällen (vgl. N 50): es ist einzig eine Schutznorm zu finden und die Widerrechtlichkeit (und damit die Aktivlegitimation) ist gegeben, auch wenn die Schädigung selbst über die Stufe einer «Zurechnungsperson» erfolgte.^{135, 136}

c) Terminologische Konsequenz

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass die Frage der Aktivlegitimation einzig noch eine Frage der Widerrechtlichkeit ist (vgl. N 45 f.), hat die Differenzierung zwischen direkten und indirekten Schaden bzw. Reflexschaden (= Schaden einer Person, der kraft Reflexwirkung der Erstschädigung entstanden ist) hinsichtlich der Anspruchsberechtigung keine Bedeutung mehr.

3.2 Gesetzliche Ausnahmen: Anspruchsberechtigung

Gemäss h.L. und Rechtsprechung sieht das Gesetz einzig zwei Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtersatzfähigkeit von Reflexschäden vor, nämlich mit **Art. 45 Abs. 3 OR** (Ersatz des Versorgerschadens) sowie **Art. 47 OR** (Genugtuung für Angehörige eines Getöteten).¹³⁷ 54

Aus den beiden gesetzlichen Ausnahmebestimmungen wird e contrario gefolgert, dass andere sog. «Reflexschäden» nicht ersatzfähig seien.¹³⁸ 55

[Seite 69] 3.3 Weitere Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtentschädigung von Reflex- bzw. Drittschäden

Neben den vorstehend erwähnten beiden gesetzlichen Ausnahmebestimmungen (vgl. N 54) werden in der Lehre und Rechtsprechung z.T. noch andere Normen bzw. spezielle rechtstechnische Wege für Reflex- und Drittschadenersatz genannt.¹³⁹ 56
Insbesondere wird für bestimmte Drittschadenskonstellationen die sog. «Drittschadensliquidation» (vgl. N 57 ff.) aus Billigkeitsgründen vertreten.¹⁴⁰ Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass dem Institut der Drittschadensliquidation im Bereich des ausservertraglichen Haftpflichtrechts in der Literatur einerseits mit Zurückhaltung begegnet wird,¹⁴¹ andererseits aber mittels dogmatisch äusserst fragwürdigen Lösungen das Institut abgelehnt wird,¹⁴² andere wiederum dezidiert die Notwendigkeit der Drittschadensliquidation vertreten, wenn die Differenztheorie (vgl. **Art. 41 OR** N 17 ff.) konsequent angewendet werde,¹⁴³ wird im Folgenden speziell auf das Institut eingegangen. Dabei wird im Besonderen auch geprüft, ob blosse Billigkeitsgründe für das Institut sprechen.

VIII. Drittschadensproblematik bzw. Drittschadensliquidation im Besonderen

A. Prinzipielle Auswirkungsmöglichkeiten einer schädigenden Handlung auf Drittpersonen

1. Terminologisches als Vorbemerkung

Die Frage der Ersatzfähigkeit von sog. «indirekten Schäden» bzw. «Reflexschäden» ist letztlich eine Frage der sog. «Drittschadensproblematik» bzw. des «Drittschadenersatzes». Im Folgenden wird deshalb konsequent von Erstscha- den/Eigenschaden und Drittschaden als Oberbegriff für verschiedene Drittschadenskonstellationen gesprochen. 57

[Seite 70] 2. Phänomenologie der Drittschadensproblematik und Drittschadensarten

Ausgangspunkt der ganzen Drittschadensproblematik ist die Erkenntnis, dass **ein und dieselbe schädigende Handlung** sich schadensmässig nicht nur bei dem von ihr direkt Betroffenen (V) auswirken kann, sondern **über ihn als Vorstufe** auch bei Drittpersonen (D).¹⁴⁴ Geht man von dieser Erkenntnis aus, so lassen sich im Verhältnis zu Drittpersonen phänomenologisch zwei prinzipielle Auswirkungsmöglichkeiten einer schädigenden Handlung feststellen, nämlich: 58

a) Schadensentstehung auch bei Drittpersonen (Drittschaden; nach hiesiger Terminologie «Reflexschaden») neben den für die schädigende und tatbestandsmässige Handlung eintretenden typischen Schadensfolgen beim direkt Betroffenen (Eigen-/Erstscha- den [im Folgenden **«allgemeine Drittschadensfälle»** genannt]), so dass festzustellen ist: Existenz eines Erstscha- dens mit eigenem Verletzungstatbestand (Widerrechtlichkeit) sowie Existenz eines nichtersatzfähigen Drittschadens wegen fehlendem eigenem Verletzungstatbestand;¹⁴⁵ sowie 59

b) nur Entstehung eines Drittschadens ohne eigenen Verletzungstatbestand und Fehlens der für die schädigende Handlung typischen Schadensfolgen bei dem vom Verletzungsereignis direkt Betroffenen (im Folgenden **«Drittschadensproblem im engeren Sinn»** genannt).¹⁴⁶ In diesen Fallkonstellationen erleidet der 60

tatbestandsmässig Verletzte aufgrund besonderer Umstände rechnerisch keinen eigenen Vermögensschaden (Tatbestandsmässigkeit ohne Vermögensschaden), hingegen aber bestimmte Drittpersonen, die jedoch ihrerseits wegen fehlender eigener Widerrechtlichkeit keinen Anspruch gegen den Schädiger besitzen (Vermögensschaden beim Dritten ohne eigene Tatbestandsmässigkeit).

Dieses Phänomen (N 60) kann infolge einer sog. «**Schadensverlagerung**» bzw. **«Verlagerung der Schadensentstehungsmöglichkeit»** bei den sog. «Gefahrenlastungsfällen» (Art. 119 Abs. 3 i.V.m. Art. 185, Art. 418m Abs. 2 oder **Art. 531 Abs. 3 OR**)¹⁴⁷ oder durch **[Seite 71] unmittelbare Drittschadensentstehung** bei den Fällen einer indirekten Stellvertretung, den Obhuts- und den Treuhandfällen auftreten.¹⁴⁸

Vorstehende Phänomenologie der Drittschadensproblematik zeigt, dass der Begriff «Drittschaden» nicht eine Frage des Schadensbegriffs betrifft, sondern das Phänomen einer vermögensmässigen Schädigung einer Drittperson, die ausserhalb jener Rechtsbeziehung steht, die durch die schädigende (und widerrechtliche) Handlung zwischen dem direkt Betroffenen und dem (handelnden) Haftpflichtigen entsteht.¹⁴⁹

Von dem eigentlichen Drittschadensproblem sind die Fälle des sog. **«Haftungsinteresses»** zu unterscheiden. Hier wird ein Geschädigter durch das schädigende Ereignis seinerseits gegenüber einem Dritten ersatzpflichtig. Den aus dieser Einstandspflicht resultierende Haftungsschaden kann der Geschädigte gegenüber seinem Schädiger geltend machen. Obwohl diese Fallkonstellation letztlich kein Drittschadensproblem beschlägt, hat der Dritte doch im Gegensatz zu den «echten» Drittschadensfällen einen eigenen Ersatzanspruch,¹⁵⁰ werden die Fälle des Haftungsinteresses als Drittschadensproblem behandelt.¹⁵¹ Grund hierfür ist wohl, dass der Dritte über den Anspruch seines Vertragspartners gegenüber dem Schädiger zum Ersatze seines Vermögensschadens gelangt oder umgekehrt formuliert: Der Schädiger haftet letztlich – phänomenologisch betrachtet – für einen Drittschaden.¹⁵²

Vom Drittschadensproblem grundsätzlich verschieden und ganz andere Rechtsprobleme rufend, sind auch jene Fallkonstellationen, in denen sich ein und dieselbe schädigende Handlung in Handlungseinheit **direkt**, also nicht über die Vorstufe des V, auch auf Drittpersonen auswirkt. Der «Drittschaden» kann dabei sowohl allein als auch mit einem «Erstschaden» auftreten.¹⁵³

[Seite 72] B. Grundsatz der Nichtentschädigung von Drittschäden und seine Rechtfertigung

Dem schweizerischen Schuldrecht fehlt anerkanntermassen eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, die Schäden Dritter als nicht ersatzfähig erklärt.¹⁵⁴ Die gesetzliche Regelung von **Art. 45 Abs. 3 OR** (Versorgerschaden), die Drittschadenersatz im Haftpflichtrecht zulässt, gilt – wie bereits gesehen (vgl. vorne N 54) – nach h.L. und Rechtsprechung als Ausnahmebestimmung, und wird von vielen – e contrario und als indirekte gesetzliche Regelung – zur Rechtfertigung des Prinzips der Nichtentschädigung für das Haftpflichtrecht herangezogen (vgl. vorne N 55).¹⁵⁵ Trotz Fehlens solcher ausdrücklicher gesetzlicher Anordnungen gilt der Satz der Nichtentschädigung als «ein rechtspolitisch gesundes Prinzip unserer Rechtsordnungen».¹⁵⁶

Gerechtfertigt wird das Prinzip der Nichtentschädigung von Drittschäden einzig indirekt durch die im ausservertraglichen Haftpflichtrecht notwendige **Kumulation von Vermögensschaden und Widerrechtlichkeit in derselben Person zur Ermittlung der Anspruchsberechtigung**. Ein ersatzfähiger Vermögensschaden kann nur dann eintreten, wenn gegenüber dem Geschädigten selbst auch widerrechtlich, d.h. tatbestandsmässig gehandelt wurde.¹⁵⁷ Nur der tatbestandsmässig Verletzte darf seinen und nur seinen Schaden liquidieren (Dogma vom Gläubigerinteresse).

C. Fehlender «sekundärer Rechtsgüterschutz» bei sog. «Drittschäden im engeren Sinn»

So sehr die Regeln zur Ermittlung der Anspruchsberechtigung bei den allgemeinen Drittschadensfällen (sog. «Reflexschäden» nach herrschender Terminologie, vgl. vorne N 59) auch zu vernünftigen Ergebnissen führen mögen (vgl. vorne N 51 f.), so sehr verkehren sie sich – ohne Korrektur – zu einem unbilligen Ergebnis bei den Drittschadensfällen i.e.S. (vgl. N 60), nämlich: Haftungsbefreiung für den Schädiger trotz seiner tatbestandsmässigen (widerrechtlichen) Handlung. **67**

[Seite 73] Wird aber anerkannt, dass das ausservertragliche Haftpflichtrecht mit der Gewährung von Schadenersatz das Korrelat zur grundrechtlich geschützten Privatautonomie darstellt, indem es auf privatrechtlicher Ebene die in diesem Zusammenhang massgebenden Grundrechte mit ihren Einrichtungsgarantien gewährleistet mittels eines «sekundären Rechtsgüterschutzes» (Schadenersatz) bei ausservertraglicher Verletzung der Integritätsinteressen eines Dritten (vgl. vorne N 6 ff.), so ist in den Drittschadensfällen i.e.S. dieser verfassungsmässig gebotene sekundäre Rechtsgüterschutz gerade nicht gewährleistet, und zwar als Folge der allgemeinen Haftungsvoraussetzungen (vgl. vorne N 66); der in **Art. 41 ff. OR** grundsätzlich vorgesehene sekundäre Rechtsgüterschutz greift hier nicht. ¹⁵⁸ **68**

Angesichts dieser Sachlage stellt sich die Frage, ob der in den Fällen eines Drittschadens i.e.S. fehlende Schadenersatzanspruch aus blossen Billigkeitsüberlegungen (vgl. vorne N 56) gewährt werden soll, oder ob nicht bereits im geltenden Haftpflichtrecht punktuell die Ersatzfähigkeit eines Drittschadens i.e.S. anerkannt, der zwingend gebotene sekundäre Rechtsgüterschutz damit erfüllt und die Regelung ausdehnungsfähig ist. Denn Billigkeitsüberlegungen sollten erst dann einsetzen, wenn rechtstechnische, dogmatische Begründungen für eine als billig anerkannte Lösung wirklich unmöglich sind. ¹⁵⁹ **69**

D. Versorgerschadenregelung als punktuelle positivrechtliche Anerkennung der Ersatzfähigkeit eines Drittschadens i.e.S.

Der Ersatz des Versorgerschadens stellt nach h.L. und Rechtsprechung eine Ausnahme dar, nach der auch bloss indirekt oder sog. «**Reflexgeschädigte**» einen Schadenersatzanspruch aus eigenem Recht erhalten (vgl. vorne N 54). **Art. 45 Abs. 3 OR** ist nach h.M. ein gesetzlich geregelter Fall eines Drittschadenersatzes für sog. «Reflexschaden». Der Anspruch leitet sich aus der tatbestandsmässigen Handlung gegen den Getöteten her. Die ausnahmsweise geschützte Drittperson muss sich das tatsächliche und rechtsgeschäftliche Verhalten des Getöteten und ihr eigenes Verhalten bis zum Schadenseintritt zurechnen lassen; der Getötete und der Dritte (Versorgte) werden somit als Einheit angesehen (vgl. zum Ganzen die Kommentierung zu **Art. 45 OR**). ¹⁶⁰ **70**

Das in der h.L. und Rechtsprechung vorhandene dogmatische Verständnis über den Versorgerschaden ist mehreren Einwänden ausgesetzt. So sehr zwar auch hier mit der h.A. einerseits die Meinung vertreten wird, **Art. 45 Abs. 3 OR** regle ausnahmsweise (beschränkten) Drittschadenersatz, so sehr ist andererseits die herrschende Qualifizierung des Versorgerschadens als sog. «Reflexschaden» und damit als Schaden, der phänomenologisch gleich einzuordnen ist wie z.B. der reflektorisch entstandene Drittschaden im Solistenfall (vgl. vorne N 51), abzulehnen. Der Versorgerschaden weist gegenüber den sog. «Reflexschäden», die sich dadurch auszeichnen, dass sie reflektorisch neben einem direkten Schaden, **[Seite 74]** d.h. neben einem Erstschaden mit eigenem Verletzungstatbestand entstehen (vgl. N 59), doch gerade den fundamentalen Unterschied auf, dass ein für die schädigende Handlung typischer Erstschaden nicht auszumachen ist, wodurch sich die eigenartige Situation ergibt, dass ein Erstschaden fehlt und sich nur einerseits ein Verletzungstatbestand ohne Schaden beim direkt Betroffenen (Versorger) und andererseits ohne eigenen Verletzungstatbestand ein Drittschaden (beim Versorgten) feststellen lässt. Bereits diese phänomenologische Erkenntnis verbietet **71**

es, den Versorgerschaden mit den sog. «Reflexschäden», z.B. den Drittschäden im Solistenfall (vgl. N 51), gleichzusetzen; der Versorgerschaden beschlägt nicht die sog. «Reflexschadenproblematik» (allgemeine Drittschadensfälle, vgl. N 59), sondern das Problem des **Drittschadens i.e.S.**

Vergegenwärtigt man sich diese phänomenologische Erkenntnis, so wird klar, dass die fast stereotyp gemachte Aussage, **Art. 45 Abs. 3 OR** sei die grosse Ausnahme vom Grundsatz der Nichtentschädigung von sog. «Reflexschäden», gar nicht zutrifft. **Die Norm beschlägt einen Fall eines ganz anderen Drittschadensphänomens**, nämlich einen **durch Verlagerung der Schadensentstehungsmöglichkeit bewirkten Drittschadens i.e.S.**¹⁶¹ Es darf wohl mit gutem Grund angenommen werden, dass das auch andernorts feststellbare Abstellen auf nur einen Teil des Entstehungsmechanismus dieses Drittschadens, nämlich auf die Reflexwirkung, den Blick für das phänomenologisch Besondere des Versorgerschadens verstellt und zur Qualifikation als sog. «Reflexschaden» geführt hat. 72

Was nun die Begründung dieser Ausnahme, insbesondere mit Billigkeitsargumenten, anbelangt,¹⁶² so ist Folgendes – und zwar unabhängig von der hier erfolgten phänomenologisch andersartigen Einordnung des Versorgerschadens – anzumerken: Ein Gesetzgeber ist zweifellos ermächtigt, aus Billigkeitsüberlegungen von seinem selbst aufgestellten Haftungssystem bzw. von Haftungsvoraussetzungen abzuweichen, um schützenswertere Interessen als z.B. ein ausnahmefreies System oder Zweckmässigkeitsüberlegungen¹⁶³ zu berücksichtigen.¹⁶⁴ Geben die Materialien zu einer Norm – wie hier – über die gesetzgeberischen Motive aber nichts her,¹⁶⁵ so darf die alleinige Berufung auf die Billigkeit zur dogmatischen Begründung der gesetzlichen Lösung aber erst – wenn überhaupt – dann einsetzen, wenn rechtstechnische Begründungen zur Erklärung der als billig anerkannten Lösung wirklich unmöglich sind. Und selbst dann aber müssen Begründungen gefunden werden, die mit dem Wortlaut und dem Zusammenhang der Gesetzesvorschriften nicht im Widerspruch stehen.¹⁶⁶ Nur auf diese Weise, also wenn die Existenz der Regelung nicht nur pauschal mit Billigkeit, sondern auch dogmatisch-technisch begründet worden ist, lassen sich nämlich die in der h.A. über den Versorgerschaden vorhandenen Widersprüche bezüglich der dogmatischen Einordnung und Ersatzfähigkeit des Versorgerschadens im Vergleich mit den übrigen sog. «Reflexschäden» vermeiden. Der h.A. ist nämlich insofern widersprüchlichkeit vorzuwerfen, als ihre Auffassung, **Art. 45 Abs. 3 OR** stelle eine aus reinem Billigkeitsgedanken resultierende Sondernorm dar, sich in keiner Art und Weise mit den von ihr gleichzeitig verlangten weiteren Haftungsvoraussetzungen und ihrer übrigen Haltung bezüglich der sog. «Reflexschäden» weder logisch noch rechtlich in Einklang bringen lässt. Denn wenn erklärt wird, hier werde ausnahmsweise für einen Schaden Ersatz gewährt, ohne dass den Geschädigten gegenüber eine widerrechtliche Handlung begangen wurde – und dies ist die Konsequenz aus der Qualifikation des Versorgerschadens als sog. «Reflexschaden» –, so führt dies letztlich zu einem Schadenersatz ohne Widerrechtlichkeit.¹⁶⁷ «Eine solche Durchbrechung eines Prinzips darf aber nicht nur nicht ausnahmsweise» aus Billigkeitsgründen, «sondern überhaupt nicht vorkommen, denn Schadenersatz ohne Widerrechtlichkeit wäre ein Widerspruch gegen das Recht».¹⁶⁸ Dass auf das Widerrechtlichkeitserfordernis nicht verzichtet werden kann, zeigen unmissverständlich aber auch der Wortlaut von **Art. 45 Abs. 3 OR** sowie die systematische Stellung der Norm. Der Wortlaut erwähnt zwar das Widerrechtlichkeitserfordernis nicht, doch darf **Art. 45 Abs. 3 OR** auch nicht als Haftungsregel, sondern **nur als Schadensberechnungsnorm** verstanden werden, die die zu ersetzenden Nachteile aufzählt.¹⁶⁹ Auf einen Verzicht auf das Widerrechtlichkeitserfordernis kann aus **Art. 45 Abs. 3 OR** jedenfalls nicht geschlossen werden. Ein solcher Verzicht schliesst insbesondere aber auch der systematische Zusammenhang der Norm aus: **Art. 45 Abs. 3 OR** steht als Ziff. V («Besondere Fälle») unter der Abteilung A (**Art. 41 OR**, «Haftung im allgemeinen») und, was noch gewichtiger ist, unter dem «2. Abschnitt: Die Entstehung¹⁷⁰ durch 73

unerlaubte Handlungen». Eine unerlaubte Handlung ist zivilrechtlich aber anerkanntermassen eine widerrechtliche. **Art. 45 Abs. 3 OR** ist somit immer nur dann an **[Seite 76]** wendbar, wenn bereits ein allgemeiner Haftungsgrund erfüllt ist,¹⁷¹ was immer eine widerrechtliche Handlung voraussetzt. Dies scheinen zwar auch die h.L. und die Rechtsprechung zu sehen, wenn sie richtigerweise eine Widerrechtlichkeit in der Person des Getöteten als Haftungs Voraussetzung verlangen. Durch ihr gleichzeitiges Festhalten an der Qualifikation des Versorgerschadens als sog. «Reflexschaden», d.h. durch die Kombination des Erfordernisses der Widerrechtlichkeit in der Person des Getöteten und der Qualifikation des Versorgerschadens als Reflexschaden, widersprechen sie sich nun aber im Vergleich mit ihrer Auffassung über die weiteren sog. «Reflexschäden»¹⁷² auch logisch. Denn es geht logisch doch nicht an, einerseits zu erklären, es werde hier ausnahmsweise kraft Sonderrecht ein sog. «Reflexschaden» ersatzfähig, also ein Schaden, dem wie den anderen Reflexschäden ein eigener paralleler Verletzungstatbestand (= eigene Widerrechtlichkeit) fehlt,¹⁷³ sowie der Versorgerschadenersatzanspruch leite sich **nicht** aus der Person des Getöteten ab,¹⁷⁴ andererseits aber eine Widerrechtlichkeit in der Person des Getöteten als von der schädigenden Handlung direkt Betroffenen zu verlangen, eine Voraussetzung also, die bei den übrigen sog. «Reflexschäden» allemal ebenfalls erfüllt ist und trotzdem deren Nichtersatzfähigkeit zu vertreten. Denn entweder ist der Versorgerschaden wirklich, wie vertreten wird, ein sog. «Reflexschaden» wie z.B. der Drittschaden im Solistenfall (vgl. N 51); dann ist aber der in der h.L. und Rechtsprechung vertretene Ausschluss der übrigen Reflexschäden von der Ersatzfähigkeit rein rechtstechnisch betrachtet¹⁷⁵ nicht mehr einsehbar, sind die Fälle diesbezüglich doch gleich. Unter dem Aspekt dieser Gleichheit blieben für den Ausschluss der übrigen Reflexschäden von der Ersatzfähigkeit somit nur Billigkeits- und Zweckmässigkeitsüberlegungen zugunsten des Schädigers übrig,¹⁷⁶ und die Billigkeit müsste nicht – wie in der h.A. – für die Begründung und Legitimierung der Versorgerschadenregelung bemüht werden, tritt doch hier nur ein und damit ein begrenzter Schaden ein (nur Drittschaden, kein Eigen-/Erstschaden), was zusätzlich Haftungsbegrenzungsüberlegungen im Vergleich zu den übrigen Reflexschäden unnötig macht.

Oder aber der Versorgerschaden ist gerade wegen des fehlenden Erstschadens¹⁷⁷ – **74** wie hier vertreten wird – kein vergleichbarer Reflexschaden, wodurch der anerkannte Ausschluss der sog. «Reflexschäden» von der Ersatzfähigkeit bereits rechtstechnisch wieder einsehbar **[Seite 77]** wird¹⁷⁸ und zusätzliche Haftungsbegrenzungsüberlegungen unnötig sind.¹⁷⁹ Dadurch ist der Weg aber auch offen, die im Ergebnis auch hier als billig qualifizierte Versorgerschadenregelung nicht nur mit Billigkeitsargumenten, sondern mit juristisch-technischen und dogmatischen, operationalen Überlegungen widerspruchsfrei zu begründen und ins System einzuordnen.

Die h.L. und Rechtsprechung sind auch insofern widersprüchlich, als sie einerseits **75** zwar richtig vertreten, es seien der Getötete und der Versorgte als Einheit zu behandeln (vgl. **Art. 45 OR** N 56), andererseits aber erklären, der Schadenersatzanspruch leite «sich nicht aus der Person des Getöteten ab».¹⁸⁰ Eine solche einheitliche Behandlung lässt sich logisch aber doch nur damit erklären, dass die Versorgten ihren Anspruch aus der gegen den Versorger begangenen tatbestandsmässigen Handlung herleiten.¹⁸¹ Dies erhellt insbesondere auch ein unbefangener Blick auf die Situation der Haftungs Voraussetzungen: Für einen Versorgerschadenersatzanspruch müssen alle anspruchsbegründenden Haftungs Voraussetzungen, ausser derjenigen des Schadens, in der Person des Getöteten erfüllt sein. Nur unter dieser Prämisse wird aber einsehbar,¹⁸² dass die

Versorgten sämtliche bei der tatbestandsmässigen Handlung mitwirkenden ersatzmindernden Umstände auch gegen sich gelten lassen müssen.¹⁸³

Zusammenfassend ist somit festzuhalten: Das in der h.L. und Rechtsprechung vorhandene dogmatische Verständnis, Art. 45 Abs. 3 OR sei die auf Billigkeitsüberlegungen beruhende grosse Ausnahme vom Grundsatz der Nichtentschädigung von sog. «Reflexschäden», trifft nicht zu. Art. 45 Abs. 3 OR gewährt zwar (beschränkten) Drittschadenersatz, jedoch nicht für einen sog. «Reflexschaden»,¹⁸⁴ sondern für einen durch Verlagerung der Schadensentstehungsmöglichkeit bewirkten **Drittschaden i.e.S.**¹⁸⁵ Nur diese Qualifikation des Versorgerschadens vermeidet den in der h.A. anzutreffenden Zwang, die Norm mit unreflektierten Billigkeitsüberlegungen zu begründen, woraus wiederum die vorstehend kritisierten Widersprüche resultieren. Es ist anzunehmen, dass der Blick auf nur einen Teil des Entstehungsmechanismus des Drittschadens, nämlich die Reflexwirkung, den Blick für das Besondere des Versorgerschadens verstellt hat. Werden jedoch alle Aspekte in die Betrachtung miteinbezogen, so wird die Besonderheit sofort offenbar und die Qualifikation des Versorgerschadens als sog. «Reflexschaden» unmöglich. Wird anerkannt, dass Art. 45 Abs. 3 OR einen Drittschaden i.e.S. punktuell als ersatzfähig regelt, so lässt sich die Norm auch widerspruchsfrei erklären und ohne Zwang und ohne zweifelhafte Billigkeitsbegründung juristisch-technisch ins bestehende System einordnen (vgl. hinten N 84 ff.).

76

[Seite 78] Der Anspruch auf Ersatz des Versorgerschadens setzt – wie jeder andere Anspruch nach Art. 41 Abs. 1 OR – eine widerrechtliche Handlung voraus. Die Anwendung von bloss der allgemeinen Haftungsvoraussetzungen (Kumulation von Vermögensschaden und Widerrechtlichkeit in derselben Person; vgl. vorne N 66) würde aber den verfassungsmässig gebotenen sekundären Rechtsgüterschutz – nämlich Schadenersatz bei widerrechtlicher Verletzung des höchsten Rechtsgutes «Leben» – wegen Wegfall des schadenfähigen Rechtssubjekts nicht verwirklichen. Zur Vermeidung dieses unter dem Aspekt eines umfassenden Rechtsgüterschutzes unakzeptablen, ja zwingend zu vermeidenden Resultats, wird mittels Art. 45 Abs. 3 OR die schadenersatzrechtlich notwendige Einheit von tatbestandsmässig Verletzten und Vermögensgeschädigten, d.h. die notwendige Kumulation von Widerrechtlichkeit und Vermögensschaden für einen ausservertraglichen Schadenersatzanspruch geschaffen. Art. 45 Abs. 3 OR liegt somit völlig auf der Linie von Art. 41 Abs. 1 OR und schafft keine Ausnahme, sondern stellt lediglich sicher, dass der durch Art. 41 Abs. 1 OR angestrebte sekundäre Rechtsgüterschutz (vgl. N 68) auch bei Auseinanderfallen der Anspruchsvoraussetzungen auf verschiedene Rechtssubjekte bzw. bei Wegfallen eines schadenfähigen Rechtssubjektes zum Tragen kommt.¹⁸⁶ **Die Norm gibt mit der Schaffung einer Anspruchsberechtigung für einen Drittschaden i.e.S. (in casu verlagerten Schaden) dem verfassungsmässig gebotenen sekundären Rechtsgüterschutz Vorrang vor den Regeln zur Bestimmung der Anspruchsberechtigung** (vgl. hierzu vorne N 44 ff.).¹⁸⁷

77

[Seite 79] *E. Notwendigkeit einer Rechtsfortbildung mittels teleologischer Extension der Anspruchsgrundlagen*

1. Bedeutung der Versorgerschadenregelung hinsichtlich der Ersatzfähigkeit der Drittschäden i.e.S.

Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass dem verfassungsmässig zwingend gebotenen sekundären Rechtsgüterschutz der Vorrang gebührt (vgl. N 77), gewinnt die Ersatzfähigkeit von Drittschäden i.e.S. punktuell anerkennende und dadurch das Problem des Auseinanderfallens von Tatbestandsvoraussetzungen punktuell lösende Norm von Art. 45 Abs. 3 OR eine eminente Bedeutung; nämlich hinsichtlich der Frage, ob sie bezüglich der Drittschadenersatz verhindernden Rechtsprinzipien (vgl. N 65 f.) eine abschliessend geregelte Ausnahme darstellt und damit ein

78

qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt, das eine Rechtsfortbildung verbietet.

Diese Frage im Wissen um die Funktion des Schadenersatzrechtes zu stellen (vgl. N 9 ff.), bedeutet, sie hinsichtlich der generellen Problematik der Drittschäden i.e.S. zu verneinen: Diese Norm kann und darf – selbst wenn der Gesetzgeber es glaubte – keine abschliessende Ausnahmeregelung darstellen, aufgrund welcher auf ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers geschlossen werden muss. Denn andernfalls würde in den übrigen Fällen eines Auseinanderfallens von Tatbestandsvoraussetzungen auf verschiedene Rechtssubjekte der verfassungsmässig zwingend gebotene Rechtsgüterschutz – trotz Verletzung einer schützenswerten Position – verunmöglicht. Mit anderen Worten: Will der sekundäre Rechtsgüterschutz bei Verletzung einer verfassungsmässig als schützenswert anerkannten Rechtsposition gewährleistet werden, so darf das Auseinanderfallen von Anspruchsvoraussetzungen auf verschiedene Rechtssubjekte hinsichtlich der Ersatzfähigkeit der hier verursachten Schäden keinen Einfluss haben. Damit kann aber auch die Ersatzfähigkeit von Drittschäden i.e.S. anerkennende positive Gesetzesregel nicht als abschliessende Ausnahmeregelung qualifiziert werden; sie ist vielmehr nur und einzig die positiv-rechtliche Regelung eines vom Gesetzgeber gesehenen Teilbereiches von Drittschäden i.e.S.: **Rechtsfortbildung ist demzufolge möglich.**

2. Notwendigkeit einer Rechtsfortbildung

Der verfassungsmässig zwingend gebotene sekundäre Rechtsgüterschutz verlangt eine **funktionsorientierte Ausgestaltung und Auslegung der Schadenersatznormen**, d.h. mit anderen Worten: zwingender Schadenausgleich bei Verletzung einer durch die Verfassung als schützenswert qualifizierten Rechtsposition (vgl. vorne N 8).

Trotz Verletzung einer solchen Position sieht das positive Recht jedoch für Drittschäden i.e.S. einen entsprechenden **generellen Anspruch nicht vor**. Bereits diese Erkenntnis gebietet für die Drittschäden i.e.S. eine entsprechende Rechtsfortbildung, ansonsten auf schadenersatzrechtlicher Ebene für diese Fälle die hier massgebenden Grundrechte mit ihren **[Seite 80]** Einrichtungsgarantien nicht garantiert wären. Unter diesem Aspekt ist die entsprechende Rechtsfortbildung gerade zwingend notwendig.

Zusätzlich ist anzumerken: Die tragenden Gründe für den grundsätzlichen Ausschluss des Ersatzes von Drittschäden – Beschränkung des Risikos des Handelnden auf überschaubare Grenzen sowie Vermeidung von Haftungskumulationen¹⁸⁸ – treffen in den Fällen eines Drittschadens i.e.S. gerade nicht zu, da der Umfang der Ersatzansprüche hier nicht wächst.¹⁸⁹ Im Weiteren ist festzuhalten: Die Beschränkung der Ersatzpflicht auf die aufgrund des herrschenden Widerrechtlichkeitsverständnisses (vgl. **Art. 41 OR** N 17 ff.) übersichtlichen, klar erkennbaren Tatbestände (z.B. Verletzung eines absoluten Rechtsgutes) ist bei den Fällen eines Drittschadens i.e.S. nicht gefährdet, da ja die Erfüllung eines solchen Tatbestandes gerade Voraussetzung des Problems ist. «Weder die Versagung eines Ersatzanspruchs bei mittelbaren Schäden¹⁹⁰ noch der grundsätzliche Ausschluss der Ersatzpflicht für allgemeine Vermögensschäden sind daher in ihrem Sinngehalt verletzt»,¹⁹¹ wenn die Drittschäden i.e.S. für ersatzfähig erklärt werden.

Die zwingend gebotene Rechtsfortbildung zur Anerkennung der Ersatzfähigkeit der Drittschäden i.e.S. lässt sich somit problemlos im Rahmen jener tragenden Gründe des positiven Rechts vornehmen, die zu den Prinzipien zur Bestimmung des Subjektes des Schadenersatzanspruches führten (vgl. vorne N 44 ff.).

3. Rechtsfortbildung mittels teleologischer Extension der Anspruchsgrundlagen für Drittschäden i.e.S.

Konsequenz der zur Ermittlung der Anspruchsberechtigung notwendigen Kumulation von Widerrechtlichkeit und Vermögensschaden in derselben Person (vgl. vorne N 66) ist, dass sich der zu ersetzende Schaden nach der Person des tatbestandsmässig Verletzten richtet und dieser nur seinen Schaden liquidieren¹⁹² bzw. seinen Vermögensschaden nicht mit einem Drittschaden begründen darf. Dieses sog. «Dogma vom Gläubigerinteresse»¹⁹³ stellt «nichts anderes als die lehrsatzmässige Abstraktion aller [...] abstrakten Einzelregelungen» dar.¹⁹⁴ Bildlich gesprochen ist das Dogma die Spitze einer Pyramide.

[Seite 81] Kollidiert der Lehrsatz allerdings mit dem verfassungsrechtlich zwingenden Gebot des sekundären Rechtsgüterschutzes in Form eines Schadensausgleichs, so muss dieser vorgehen, damit eine als grundsätzlich schützenswert qualifizierte, aber verletzte Rechtsposition nicht schutzlos bleibt. Die damit notwendigerweise verbundene Einschränkung des Dogmas vom Gläubigerinteresse darf dabei aber nicht durch eine «teleologische Reduktion» dieses Verbots erfolgen, indem aus dem Dogma des Verbotes eines Drittschadenersatzes Ausnahmen herausgebrochen werden. Es sind vielmehr – analog der Versorgerschadenregelung – die Drittschäden i.e.S. mittels einer **«teleologischen Extension»** der einzelnen Anspruchsgrundlagen, die den Schadenersatz auf den Schaden des in seinen Rechten tatbestandsmässig Verletzten beschränken»,¹⁹⁵ generell in die Ersatzpflicht miteinzubeziehen. Denn die Tatbestände eines Drittschadens i.e.S. stehen wertungsmässig auf derselben Ebene wie die sog. «Normalfälle». In beiden Tatbestandsvarianten ist eine von der Verfassung als schützenswert qualifizierte Position (z.B. absolutes Rechtsgut) in derselben Weise verletzt. Warum aber der über die Grundrechte von der Verfassung her prinzipiell auch auf privatrechtlicher Ebene gebotenen Rechtsgüterschutz in Form eines zwingenden Schadensausgleichs nur in den «Normalfällen» und nur in einem vom Gesetzgeber mehr oder weniger bewusst gesehenen Teilbereich von Drittschäden i.e.S. (**Art. 45 Abs. 3 OR**) gelten soll, nicht aber grundsätzlich auch bei den übrigen, gegenüber den «Normalfällen» und **Art. 45 Abs. 3 OR** von der Interessenbewertung her gleichartigen Drittschäden i.e.S., ist jedenfalls nicht einsehbar und auch nicht begründbar. Das verfassungsmässig zwingende Gebot des Schadensausgleichs bei Verletzung einer als schützenswert qualifizierten Rechtsposition – was gerade auch hier der Fall ist – verlangt somit, wie in den sog. «Normalfällen», grundsätzlich – und nicht nur im Fall von **Art. 45 Abs. 3 OR** – die Gewährung eines Schadenersatzanspruchs für Drittschäden i.e.S. **Die positiv-rechtlichen Anspruchsgrundlagen von Art. 41 Abs. 1 OR (bzw. Art. 97 Abs. 1 OR), die nach dem herrschenden Verständnis den Schadenersatz auf den Schaden des tatbestandsmässig Verletzten beschränken, sind folglich – analog zu der Drittschadenersatz anerkennenden Norm von Art. 45 Abs. 3 OR¹⁹⁶ – hinsichtlich der Anerkennung der Ersatzfähigkeit von Schäden auf die Drittschäden i.e.S. auszudehnen (teleologische Extension der Anspruchsgrundlagen).**

Wird aber anerkannt, dass ein Drittschaden i.e.S. aufgrund des verfassungsmässig zwingend gebotenen Schadensausgleichs bereits im Rahmen von **Art. 41 Abs. 1 OR** grundsätzlich ersatzfähig ist, so ist es – in Analogie zu **Art. 45 Abs. 3 OR**, der unter einem beschränkten Gesichtspunkt die schadenersatzrechtlich notwendige Einheit von tatbestandsmässig Verletzten und Vermögensgeschädigten herstellt – nur noch ein kleiner Schritt zur generellen Folgerung für die Drittschäden i.e.S., nicht den tatbestandsmässig Verletzten, sondern den **[Seite 82]** statt dessen Drittgeschädigten als anspruchsberechtigt anzusehen.¹⁹⁷ CANARIS führt in diesem Zusammenhang auch Zweckmässigkeitsüberlegungen an: «So würde der widersinnige Umweg über den unmittelbar Verletzten, aber nicht Geschädigten vermieden; auch lässt sich auf diese Weise z.B. ohne weiteres verhindern, dass der «Anspruchsberechtigte» den Schaden

ohne den Willen des wahren Geschädigten geltend macht und sich so u.U. bereichert. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auch das Gesetz, wo es Drittschadensersatz gewährt, den Geschädigten und nicht den unmittelbar Verletzten als anspruchsberechtigt ansieht.»¹⁹⁸

Aufgrund des verfassungsmässig zwingend gebotenen Schadensausgleichs, aus Praktikabilitätsgründen sowie aus Gründen der Gleichbehandlung ist **Art. 41 Abs. 1 OR** deshalb – schon de lege lata – wie folgt zu lesen: «Wer einem andern widerrechtlich **oder statt diesem einem Dritten** Schaden zufügt, [...], wird ihm **oder dem statt dessen Geschädigten** zum Ersatze verpflichtet.»^{199, 200} **Die für einen Schadenersatzanspruch notwendige Einheit von tatbestandsmässig Verletztem und Vermögensgeschädigten wird dadurch geschaffen.** 87

Will man hingegen dieser durch teleologischer Extension gewonnene Anwendbarkeit von **Art. 41 Abs. 1 OR** auch auf Drittschäden im engeren Sinne nicht folgen, so sind, nicht aus blossen Billigkeitsgründen, sondern als Folge des verfassungsmässig garantierten sekundären Rechtsgüterschutzes, die Drittschäden i.e.S. mittels der sog. «Drittschadensliquidation»²⁰¹ zwingend zu ersetzen.²⁰² 88

Fussnoten:

- 1 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 1, welche zwar nicht von «Schadenersatz-», sondern von «Schadensrecht» sprechen, vgl. hierzu aber N 3.
- 2 So u.a. REY, Rz 30 ff. i.V.m. 2.
- 3 KELLER/GABI/GABI, S. 2.
- 4 BERGER, Rz 1830 ff.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 2 und 8 ff.; KELLER/GABI/GABI, S. 3; OFTINGER/STARK I, § 1 Rz 6; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 1.
- 5 KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 1; SCHWENZER, Rz 49.01.
- 6 REY, Rz 11.
- 7 So u.a. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 2.
- 8 MERTENS, S. 11, Fn 1: «Unter dem Oberbegriff Schadenersatzrecht» wird unterschieden zwischen dem «Recht der Haftungsbegründung (Haftungsrecht) als den Rechtsbereich, der sich mit den Gründen der Schadenersatzpflicht befasst», und dem «Recht der Schadenszurechnung (Schadensrecht) als den Inbegriff der Rechtssätze, die den Inhalt der Schadenersatzpflicht bestimmen». Ebenso HAGEN, S. 178 («Es [sc. das Schadensrecht] legt fest, in welchem Umfang dem Betroffenen ein Ausgleich zu gewähren ist [...]») und S. 26 («Bietet das *Haftungsrecht* keine allgemeine Grundlage [...], so liegt es nahe aus dem *Schadensrecht* heraus [...]»).
- 9 ROBERTO, Schadensrecht, S. 1 ff.; sinngemäss ebenso KADNER GRAZIANO, S. 1 ff. (11–18).
- 10 KELLER/GABI/GABI, S. 3.
- 11 KELLER/GABI/GABI, S. 3.
- 12 Ebenso HAGEN, S. 26 und 178; KADNER GRAZIANO, S. 11 ff.; KEUK, S. 9 ff.; MAGNUS, S. 28 ff.; ROBERTO, Schadensrecht, S. 9 ff.
- 13 MÜLLER-CHEN, S. 294; vgl. zum Integritätsinteresse hinten N 6.
- 14 Vgl. statt vieler HUGUENIN, Rz 848 ff. (852 und 866) i.V.m. 97 ff.
- 15 Ebenso MÜLLER-CHEN, S. 290.
- 16 BERGER, Rz 52 und 166.
- 17 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 7.
- 18 Sinngemäss gl.M. MÜLLER-CHEN, S. 292 m.V. auf VON BAR, S. 331.
- 19 MÜLLER-CHEN, S. 294.
- 20 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 57.
- 21 BERGER, Rz 1830; REY, Rz 717 (Zufallskontakt).
- 22 REY, Rz 3; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 2; SCHWENZER, Rz 49.01.

- 23 Vgl. statt vieler KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 2.
- 24 OFK-FISCHER, Art. 41 OR N 4; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 3. Zur Anspruchskonkurrenz vgl. Art. 41 OR N 3 ff.
- 25 HUGUENIN, Rz 1839.
- 26 Gl.M. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 34: Es grenzt die «Rechtskreise der Einzelnen, innerhalb deren sie ihre individuelle Freiheit entfalten und ihre Interessen verfolgen dürfen», voneinander ab.
- 27 So schon WIDMER P., S. 312.
- 28 Gl.M. BULLINGER, S. 302.
- 29 BULLINGER, S. 299; sinngemäss gl.M. HONSELL, Entwicklungstendenzen, S. 15.
- 30 Demgegenüber ist primäres Schutzobjekt im Vertragsrecht das im Vertrag (ausdrücklich oder konkludent) definierte Erfüllungsbzw. Äquivalenzinteresse beider Parteien. Die Parteien können jedes vermögensmässige Interesse oder aber auch andere Interessen zum schützenswerten Interesse («Rechtsgut») erheben. Sofern die Parteien keine oder ungenügende Sanktionsregeln für Vertragsverletzungen vereinbart haben, stellt das Vertragsrecht mit den allgemeinen Leistungsstörungsregeln und bspw. den Gewährleistungsnormen ein dispositives Leistungsstörungssystem zur Verfügung. Über das hierdurch geschützte Erfüllungsbzw. Äquivalenzinteresse hinaus integrierte die Rechtsprechung – in einer gewissen Anomalie zum System des vertraglichen Haftpflichtrechts – über die auf das Integritätsinteresse ausgerichteten Nebenpflichten das Integritätsinteresse selbst in den vertraglichen Schutzbereich (positive Vertragsverletzung). Dadurch werden mit dem vertraglichen Haftpflichtrecht auch Rechtsgüter geschützt, die den Vertragsparteien vertragsunabhängig zustehen (vgl. zum Ganzen MÜLLER-CHEN, S. 289 ff., insb. S. 295 f. mit Begründung für die Belastung des Vertragspartners mit diesem zusätzlichen Haftungsrisiko; vgl. hierzu auch FELLMANN/KOTTMANN, Rz 37–40).
- 31 KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 2.
- 32 Vgl. statt vieler HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 4 i.V.m. § 10 Rz 1; KELLER/GABI/GABI, S. 3; sinngemäss gl.M. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 67; HUGUENIN, Rz 1829 i.V.m. 1899.
- 33 KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 2 m.V. auf VON TUHR/PETER, S. 407.
- 34 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 3; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 63; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 4; MÜLLER-CHEN, S. 291; REY, Rz 12; ROBERTO, Rz 02.65; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 4; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 3.
- 35 BGE 131 III 12, E. 6.1 und 7.1; BGER 4A.127/2011, E. 10.1; 5C.7/2001, E. 6; BK-BREHM, Art. 43 OR N 25; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 1336 und 1750; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 64; REY, Rz 13; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 3.
- 36 Zur Durchbrechung des Bereicherungsverbotes wie der Abzug «neu für alt» vgl. Art. 42 OR N 49.
- 37 REY, Rz 14 m.V.; ebenso KÖTZ, S. 644; OFTINGER/STARK I, § 1 Rz 15.
- 38 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 3; ebenso FELLMANN, SJZ 1995, S. 44 f.
- 39 FELLMANN, SJZ 1995, S. 44 f.; ebenso SCHWENZER, Rz 49.04: «Tragend ist heute m.E. der Gesichtspunkt der Prävention [...]».
- 40 SCHWENZER, Rz 49.04; vgl. auch HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 66; MÜLLER-CHEN, S. 292 f.; ROBERTO, Rz 02.74; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 4.
- 41 REY, Rz 15.
- 42 So KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 4.
- 43 REY, Rz 16.
- 44 Gl.M. BULLINGER, S. 303.
- 45 KÖTZ, S. 645.
- 46 BULLINGER, S. 303; KÖTZ, S. 645.
- 47 FELLMANN, SJZ 1995, S. 44: «Es geht [...] um die Gestaltung der Lebensbedingungen, um die Steuerung des Verhaltens von Einzelnen und Gruppen»; sinngemäss gl.M. ROBERTO, Rz 02.71–02.74.

- 48 LARENZ, S. 865.
- 49 GL.M. BULLINGER, S. 303; DEUTSCH, JZ 1971, S. 247. Vgl. auch den interessanten Nachweis des Präventionszweckes im Rahmen der Haftungsbegründung anhand des Deliktsaufbaus bei DEUTSCH, JZ 1971, S. 247: «Die Aufbaureihe ‹Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Verschulden› ist an der Verhinderung des Eingriffs orientiert und wird in erster Linie vom Präventionszweck getragen.»
- 50 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 3; OFTINGER/STARK I, § 1 Rz 34; REY, Rz 17; ROBERTO, Rz 02.79; SCHWENZER, Rz 49.04.
- 51 CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 4; REY, Rz 17 m.w.V.; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 5.
- 52 REY, Rz 17; VON TUHR/PETER, S. 104.
- 53 Die Möglichkeit der Reduktion des Schadenersatzes bei geringem Verschulden wird deshalb auch als inkonsequent gerügt, vgl. ROBERTO, Rz 02.83.
- 54 REY, Rz 17.
- 55 OFTINGER/STARK I, § 1 Rz 11.
- 56 BERGER, Rz 1831; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 5; OFK-FISCHER, Art. 41 OR N 1; KELLER/GABI/GABI, S. 1; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 4.
- 57 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 1.
- 58 REY, Rz 20.
- 59 MÜLLER-CHEN, S. 292, der zusätzlich richtigerweise darauf hinweist, dass das «Haftpflichtrecht [...] seiner Funktion nach nicht Sozialrecht» ist.
- 60 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 6 und 44.
- 61 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 44.
- 62 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 44.
- 63 MÜLLER-CHEN, S. 291.
- 64 MÜLLER-CHEN, S. 291.
- 65 REY, Rz 19.
- 66 REY, Rz 48.
- 67 REY, Rz 50 und 805; OFTINGER I, S. 37. Beispielhaft für diese Uneinheitlichkeit führt REY, Rz 53, für die Tierhalterhaftpflicht (Art. 56 OR) «die Verletzung der Verwahrungs- und Beaufsichtigungspflicht» und für die Grundeigentümerhaftpflicht (Art. 679 ZGB) «das Überschreiten der aus dem Grundeigentum fliessenden Nutzungsbefugnisse» an.
- 68 Zu den einzelnen Zurechnungskriterien bei den Kausalhaftungen siehe hinten N 26.
- 69 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 25 und 27; ebenso BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1; REY, Rz 77; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 9.
- 70 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 28 ff.; KELLER/GABI/GABI, S. 5 f.; REY, Rz 95; grundlegend BGE 16 I 409.
- 71 REY, Rz 56; vgl. zu den verschiedenen Anknüpfungstatbeständen hinten N 26.
- 72 OFK-FISCHER, Art. 41 OR N 2; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 8; KELLER/GABI/GABI, S. 3; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 5 und 16; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 7.
- 73 REY, Rz 58; sinngemäss HUGUENIN, Rz 1830.
- 74 REY, Rz 58 und 97 ff.; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 14 und 32 f.
- 75 Danach sind **milde (einfache) Kausalhaftungen**: Art. 54 Abs. 2, Art. 55, 56 und 59a OR, Art. 333 ZGB; **scharfe (einfache) Kausalhaftungen**: Art. 54 Abs. 1 und Art. 58 OR, Art. 679 ZGB, Produkthaftung gemäss PrHG.
- 76 So u.a. HUGUENIN, Rz 1836–1838; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 228; dem Sinne nach ebenso, wobei der Begriff scharfe (einfache) Kausalhaftung vermieden wird, BK-BREHM, Art. 54 OR N 8 (weder Gefährdungshaftung noch vergleichbar mit Art. 55, 56 OR, Art. 333 ZGB), Art. 55 OR N 32 («milde Kausalhaftung»), Art. 56 OR N 31 («milde Kausalhaftung»), Art. 58 OR N 92 («strenge Kausalhaftung»).

- 77 KELLER A., Haftpflichtrecht I, S. 48 ff.; CHK-MÜLLER, **Art. 41 OR** N 16–18; OFTINGER/STARK I, § 1 Rz 39 f.
- 78 OFTINGER/STARK I, § 21 Rz 25.
- 79 KELLER/GABI/GABI, S. 73 (Hervorhebung durch Verfasser); ferner OFK-FISCHER, **Art. 41 OR** N 2.
- 80 Zusammenstellung aus KELLER/GABI/GABI, S. 74.
- 81 **BGE 102 II 33; 101 II 346; 93 II 111.**
- 82 **BGE 104 II 23; 102 II 232.**
- 83 **BGE 102 II 23.**
- 84 Durch Verweis auf das EBG; vgl. die entsprechende Kommentierung.
- 85 **BGE 81 II 558; 63 II 111.**
- 86 **BGE 103 II 240; 102 II 343; 110 II 132; 96 II 34; 94 II 151.**
- 87 **BGE 104 II 15; 91 II 474.**
- 88 **BGE 97 II 22; 96 II 27.**
- 89 **BGE 103 II 24; 100 II 298; 79 II 350; 70 II 13.**
- 90 KELLER/GABI/GABI, S. 74 für **Art. 54 OR**.
- 91 **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 10** für **Art. 15 JSG** und **Art. 137 MG**. Dasselbe gilt aber auch für das GTG, vgl. die entsprechende Kommentierung.
- 92 Zu den einfachen Kausalhaftungen gehören nach h.M. die **Haftung des Urteilsunfähigen (Art. 54 OR)**, die **Geschäftsherrenhaftung (Art. 55 OR)**, die **Tierhalterhaftung (Art. 56 OR)**, die **Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR)**, die **Familienhauptshaftung (Art. 333 ZGB)**, die **Grundeigentümerhaftung (Art. 679 ZGB)**, die **Produktheftpflicht** gemäss PrHG, die **Haftung für Signaturschlüssel (Art. 59a OR)**, die **Haftung des Gläubigers gegenüber Dritten (Art. 273 SchKG)** sowie die **Haftung nach dem Strahlenschutzgesetz (Art. 39 StSG)**, vgl. statt vieler FELLMANN/KOTTMANN, Rz 24.
- 93 KELLER/GABI/GABI, S. 74 f.
- 94 HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 23; HUGUENIN, Rz 1835; ROBERTO, Rz 02.22 (sogar für **Art. 58 OR**); **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 9**; SCHWENZER, Rz 49.09.
- 95 **KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Vor Art. 41–61 N 9**, unter Verweis auf HONSELL HEINRICH, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich 2005, § 1 Rz 23, wo aber nichts Derartiges für Normen ohne Entlastungsbeweis angeführt wird.
- 96 Ebenso für Verschuldenshaftung mit Beweislastumkehr bei **Art. 58 OR**: SCHWENZER, Rz 49.09, mit dem Argument, Verschulden sei zwar nicht Voraussetzung, verlangt werde aber «Mangelhaftigkeit des Werkes, was faktisch zumeist einem Verschulden gleichkommt», was auch für **Art. 1 PrHG** gelte. Ja sogar für die in den Sondergesetzen geregelten Gefährdungshaftungen sei unter bestimmten Umständen eine Entlastung vorgesehen. Demgegenüber ordnen SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 229 und 274, **Art. 54 und 58 OR, Art. 679 ZGB** sowie die Produktheftung zwar unter die einfachen, hier jedoch unter die scharfen Kausalhaftungen ein, da ein Sorgfaltsbeweis hier nicht zur Verfügung steht (vgl. bereits vorne Fn 75).
- 97 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 670.
- 98 Gl.M. KELLER/GABI/GABI, S. 75.
- 99 KELLER/GABI/GABI, S. 168 (Hervorhebung durch Verfasser).
- 100 Sinngemäss gl.M. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 670; KELLER/GABI/GABI, S. 168; OFTINGER/STARK II/1, § 20 Rz 3; REY, Rz 901 («Andererseits ist die «Unsorgfalt» des Geschäftsherrn in einem weitergehenden Ausmass objektiviert als das Verschulden bei der Verschuldenshaftung»).
- 101 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 671; **BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 1**; KELLER/GABI/GABI, S. 76 f., 168 f., 179 und 184; CHK-MÜLLER, **Art. 41 OR** N 17 (sinngemäss), **Art. 55 OR** N 2 und **Art. 58 OR** N 1; OFTINGER/STARK II/1, § 20 Rz 3; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 231, mit zusätzlichem Hinweis auf die unterschiedlichen Folgen der Beweislosigkeit hinsichtlich des Verschuldens.
- 102 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 670.
- 103 Gl.M. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 670; KELLER/GABI/GABI, S. 179.

- 104 BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 58 N 3; KELLER/GABI/GABI, S. 184; CHK-MÜLLER, Art. 58 OR N 2; OFTINGER/STARK II/1, § 19 Rz 67.
- 105 BK-BREHM, Art. 56 OR N 32 und Art. 58 OR N 101; KELLER/GABI/GABI, S. 184; CHK-MÜLLER, Art. 58 OR N 2; OFTINGER/STARK II/1, § 19 Rz 67; REY, Rz 1028.
- 106 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 231; vgl. BGE 110 II 456, E. 2; sinngemäss gl.M. BK-BREHM, Art. 55 OR N 31 f., Art. 56 OR N 31 und Art. 58 OR N 90; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 OR N 1; KELLER/GABI/GABI, S. 75, 168 f., 179 und 184; REY, Rz 881.
- 107 CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 19.
- 108 KELLER/GABI/GABI, S. 10; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 19; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 6.
- 109 KELLER/GABI/GABI, S. 10.
- 110 Vgl. zum Ganzen KELLER/GABI/GABI, S. 59 ff.
- 111 BGE 105 II 289, E. 5.a.
- 112 BGE 101 II 73, E. 2; KELLER/GABI/GABI, S. 178.
- 113 BGE 124 III 363, E. II.2.
- 114 BGE 103 II 330, E. 3.
- 115 BGE 122 III 225, E. 4.b.
- 116 Vgl. statt vieler BK-BREHM, Art. 41 OR N 16.
- 117 Vgl. zu den Schadensentstehungsmöglichkeiten hinten N 58 ff.
- 118 Als Gegensatz zu den Begriffen «Reflexschaden» und «Drittschaden» (vgl. hinten N 51 ff.).
- 119 BK-BREHM, Art. 41 OR N 17; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 8; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 51; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 27; REY, Rz 350; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 61; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 10.
- 120 BK-BREHM, Art. 41 OR N 17; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Rz 03.20.
- 121 BGE 102 II 85, E. 6.c; BK-BREHM, Art. 41 OR N 17; FELLMANN/KOTTMANN, Rz 145; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 8; HUGUENIN, Rz 1873 f. (sinngemäss); REY, Rz 352; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 11.
- 122 SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 63.
- 123 BGE 57 II 180; siehe auch BGE 104 II 95, E. 2.a; 101 Ib 252, E. 2.a; 99 II 221, E. 2; 82 II 36, E. 4.a; 71 II 225, E. 1; 63 II 18, E. 5.
- 124 BGE 138 III 174; 112 II 118, E. 5; ebenfalls für Eigenschaden sind: FELLMANN/KOTTMANN, Rz 146; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 9; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 47a; HUGUENIN, Rz 1875; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 27; REY, Rz 353; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 63.
- 125 Mit Hinweis, dass es sich letztlich um einen Reflexschaden handle: KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 11; SCHWENZER, Rz 14.21; ebenso BK-BREHM, Art. 41 OR N 24: «[...] liegt gleichzeitig auch eine direkte, widerrechtliche Folge der Handlung des Geschädigten vor, die neben dem Direktgeschädigten noch ein weiteres Opfer in dessen Persönlichkeit verletzt hat». BREHM spricht deshalb a.a.O. auch von einem «**unechten Reflexschaden**» (Hervorhebung durch Verfasser); LANDOLT, Schockschäden, S. 376, der von «mittelbaren Direktschäden» spricht.
- 126 Vgl. zur Schockschadensproblematik grundsätzlich FISCHER, Schockschäden, S. 1 ff.; FISCHER/BÖHME, S. 16 ff.; WEBER S., HAVE 2012, S. 288 ff.
- 127 JAUN, S. 749 und 751.
- 128 BGE 112 II 118, E. 5.
- 129 Vgl. auch FISCHER, Schockschäden, S. 54 ff.
- 130 BGE 102 II 85; 101 Ib 252.
- 131 Was Widerrechtlichkeit bedeuten würde, vgl. Art. 41 OR N 63.
- 132 BK-BREHM, Art. 41 OR N 17a; REY, Rz 360–362 (ausnahmsweise werde ein Reflexschaden ersatzfähig durch extensive Auslegung des Schutzzweckes besonderer Verhaltensnormen); SCHWENZER, Rz 14.21 (weist aber darauf hin, dass bei «unvoreingenommener Betrachtungsweise ein Reflexschaden» vorliege).

- 133 Beispiel aus FELLMANN/KOTTMANN, Rz 144.
- 134 FELLMANN/KOTTMANN, Rz 145 m.V. auf SCHWENZER, Rz 14.22.
- 135 Gl.M. FELLMANN/KOTTMANN, Rz 146 f.
- 136 Der Entscheid betr. der Ersatzfähigkeit eines Drittschadens einzig anhand der Erfüllung der allgemeinen Haftungsvoraussetzungen (in casu Widerrechtlichkeit) und nicht mehr anhand des Entstehungsmechanismus (direkter Schadenseintritt oder nur kraft Reflexwirkung) ist zwar zu begrüssen. Allerdings ist zuzugeben, dass sich insb. bei den Stromkabelfällen ein Wertungswiderspruch einstellt, wenn man Art. 239 StGB (Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen) den privatrechtlichen Schutzgehalt abspricht (gegen diesen Schutzzweck auch LANDOLT, Ausservertragliche Haftung, S. 85), nämlich: Haftung bei Drittsachschaden, Haftungsverneinung bei reinem Drittvermögensschaden, obwohl in beiden Fällen gleichermaßen der durch den Schädiger verursachte Stromausfall Schadensursache ist.
- 137 **Betr. Art. 45 und 47 OR:** BK-BREHM, Art. 41 OR N 19 und Art. 45 OR N 28 sowie 31; CHK-MÜLLER, Art. 41 OR N 27; REY, Rz 284, 357 und 359; **nur betr. Art. 45 OR:** BGE 127 III 403, E. 4.b.aa; 112 II 118, E. 5.b; 99 II 221; FREI A., S. 29, Fn 4; FRIEDRICH, S. 78 ff.; GIOVANNONI, S. 36; BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 N 8 und Art. 45 N 7; HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 51; KELLER/GABI/GABI, S. 78 und 100; SCHNYDER/PORTMANN/MÜLLER-CHEN, Rz 64; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 10; SCHWENZER, Rz 14.20; SPIRO, S. 301; TANDOGAN, S. 309; THORENS, S. 31; VON TUHR/PETER, S. 433 f.; ZEN-RUFFINEN, S. 20. – A.M. GELPKE, S. 48, und MAYR, S. 25: Nach diesen Autoren ist Art. 45 Abs. 3 OR nicht eine Ausnahme, sondern eine Ergänzung zu Art. 41 OR.
- 138 Vgl. statt vieler BK-BREHM, Art. 41 OR N 19; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 10; SCHWENZER, Rz 14.20.
- 139 Vgl. die kommentierte Zusammenstellung bei BK-BREHM, Art. 41 OR N 20 ff.
- 140 So u.a. REY, Rz 364; SCHWENZER, Rz 14.25 («[...] erscheint es als stossend [...]»). – Vgl. zur Drittschadensliquidation allgemein: ARMBRÜSTER, S. 86 f.; ARMBRÜSTER, FS Wiegand, S. 79 ff.; BK-WEBER, Art. 97 OR N 300 ff.; für das Vertragsrecht neuestens MARTI-SCHREIER, Rz 1 ff., insb. Rz 16–21 und 62 ff.
- 141 BK-BREHM, Art. 41 OR N 26; REY, Rz 369; KUKO OR-SCHÖNENBERGER, Art. 41 N 11.
- 142 Bspw. in den Fällen von Art. 185 OR durch Kreierung eines auf Art. 2 Abs. 2 ZGB gestützten Anspruchs des Käufers auf Abtretung des (letztlich inhaltsleeren) Anspruchs des Verkäufers gegen den Haftpflichtigen, so BK-BREHM, Art. 41 OR N 23.
- 143 So SCHWENZER, Rz 14.26.
- 144 Die Tatsache der Existenz nur einer schädigenden Handlung und nur gegen V ist nicht nur Kennzeichen, sondern auch Erfordernis der Drittschadensproblematik. Zu den Ausnahmen vgl. hinten N 64.
- 145 Beispiel Solistenfall, vgl. vorne N 51.
- 146 **Beispiel 1:** «Die Ware, die der Verkäufer an die Käuferin versendet, wird auf dem Transport durch Verschulden der Transportpersonen beschädigt. Der Verkäufer hat keinen Schaden, weil er aufgrund Gefahrenübergangs nach Art. 185 Abs. 2 OR den Kaufpreisanspruch gegenüber der Käuferin behält; die Käuferin hat keinen Anspruch gegen den Transporteur, weil sie weder Vertragspartnerin noch im Zeitpunkt der Beschädigung der Ware Eigentümerin derselben ist» (SCHWENZER, Rz 14.24). **Beispiel 2:** Das bereits verkaufte Reitpferd wird zwischen Vertragsabschluss (Gefahrenübergang) und Erfüllung «Opfer» eines Brandanschlages auf die Stallungen des Verkäufers. Aufgrund von Art. 185 Abs. 2 OR hat der Verkäufer keinen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 Abs. 1 OR gegenüber dem Brandstifter (mangels Schadens) und der Käufer, der den Kaufpreis bezahlen muss, zwar einen Vermögensschaden. Ihm gegenüber wurde jedoch nicht widerrechtlich gehandelt, da er noch nicht Eigentümer ist.
- 147 Vgl. statt vieler BK-GIGER, Art. 185 OR N 14; HAGEN, S. 70; KELLER/LÖRTSCHER, S. 22 ff. (24 f.); KELLER/SIEHR, S. 23 ff.; MARTI-SCHREIER, Rz 176 ff.

- 148 Die Tatsache, dass ein Drittschaden i.e.S. sowohl Folge einer verlagerten Schadensentstehungsmöglichkeit als auch unmittelbare Folge einer schädigenden Handlung sein kann, weil es a priori um das Interesse des Dritten geht, verbietet es, diese Fallgruppen gesamthaft als Schadensverlagerungsfälle zu behandeln. Ebenso wenig darf zur Typisierung auf eine mögliche Reflexwirkung abgestellt werden, weil auch dieses Phänomen nicht in allen Fällen vorkommt. Bspw. geht es im Rahmen einer Sicherungstreuhand bei der Verletzung des Treugutes beim Treuhänder immer und a priori um das Interesse des Treugebers. Nur er kann einen Schaden erleiden und die Schadensentstehungsmöglichkeit ist von vornherein beim Treugeber und nicht vom Treuhänder auf ihn verlagert bzw. Folge eines Reflexes der schädigenden Handlung (sinngemäss gl.M. MARTI-SCHREIER, Rz 158 ff.).
- 149 Gl.M. KELLER/GABI/GABI, S. 18.
- 150 Sinngemäss gl.M. HONSELL/ISENRING/KESSLER, § 1 Rz 52; KELLER/GABI/GABI, S. 78.
- 151 BARTH, S. 85; BK-BREHM, Art. 41 OR N 21a und 25a; FREI A., S. 76; TANDOGAN, S. 307; THORENS, S. 31; VON CAEMMERER, S. 370; VON TUHR/ESCHER, S. 110; YUNG, S. 306. – A.M. BEMM, S. 27 f. (Haftungsschaden ist kein Drittinteresse).
- 152 BK-BREHM, Art. 41 OR N 25a, spricht von einer «besondere[n] Form der sog. «Drittschadensliquidation»»; KELLER/GABI/GABI, S. 18.
- 153 Als Beispiel sei der Droschkenfall angeführt: V mietet eine Droschke bei S und nimmt seinen Freund (D) auf die Fahrt mit. Der Kutscher X verursacht verschuldet einen Unfall. Sowohl V als auch D erleiden einen Schaden. Hier stellt sich die Frage, ob V den Schaden des D auch vertraglich bei S liquidieren kann, und zwar nach Art. 101 OR, bzw. ob D selbst einen vertraglichen Anspruch gegen S hat, obwohl er nicht Vertragspartner ist (Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter; vgl. hierzu BERGER, Rz 1584; HUGUENIN, Rz 1571; MARTI-SCHREIER, Rz 300 ff.), oder ob ihm nur die ausservertraglichen Ansprüche sowohl gegen S (Art. 55 OR) als auch gegen X (Art. 41 OR) verbleiben. Vgl. hierzu VON TUHR/ESCHER, S. 112.
- 154 Vgl. statt vieler für das **Haftpflichtrecht** MAYR, S. 25: «Il n'y a pas de principe selon lequel le dommage indirect n'est pas indemnisable, pas plus qu'il n'y a de principe contraire»; für das **Vertragsrecht** BK-KRAMER, Allg. Einleitung N 45: «Dieser Relativitätsgrundsatz [aus dem für das Vertragsrecht das Prinzip der Nichtentschädigung von Drittschäden abgeleitet wird (der Verfasser)], der im OR [...] lediglich aus Indizien abgeleitet werden kann»; DESCHENAUX, S. 416.
- 155 So u.a. BK-BREHM, Art. 41 OR N 19, unter Zitierung von TERCIER (S. 256) für seine Meinung. TERCIER spricht in diesem Kontext zwar davon, dass man zwar den Umkehrschluss ziehen könne und verweist auf entsprechende Autoren, lehnt diesen Schluss jedoch selbst ab (S. 257).
- 156 Vgl. statt vieler VON CAEMMERER, S. 343 und 346; BK-BREHM, Art. 41 OR N 22b: «Diese Abgrenzung zwischen Direkt- und Reflexgeschädigten [...] stellt eine «vernünftige Grenze» dar».
- 157 Zu den entsprechenden Prinzipien im Vertragsrecht wie Relativität der Schuldverhältnisse sowie Dogma vom Gläubigerinteresse vgl. statt vieler MARTI-SCHREIER, Rz 1 ff. mit umfassender Literaturangabe.
- 158 Zur analogen Situation im Vertragsrecht vgl. KUKO OR-THIER, Art. 97 N 29 ff.; BK-WEBER, Art. 97 OR N 284 ff., insb. N 296 ff.; BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 40.
- 159 Gl.M. sinngemäss MÖHRING, S. 78.
- 160 Gl.M. DEUTSCH, Haftungsrecht, Rz 921.
- 161 Gl.M. FIKENTSCHER, S. 305 (FIKENTSCHER/HEINEMANN, Rz 611, sprechen neu nicht mehr von Verlagerung der Schadensentstehungsmöglichkeit, qualifizieren aber die §§ 844 und 845 BGB ebenfalls – wie die Drittschadensliquidationsfälle – als Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtentschädigung von Drittschäden); MARTI, S. 6 und 77.
- 162 Vgl. statt vieler FREI A., S. 33 f. und 40.
- 163 Z.B. Haftungsbegrenzung.
- 164 Bsp. Art. 54 OR, der aus Billigkeitsüberlegungen die Haftung auch des Urteilsunfähigen anordnet und dadurch auf die Haftungsvoraussetzung der Urteilsfähigkeit des Schädigers, d.h. auf das Verschuldenserfordernis, verzichtet; vgl. statt vieler KELLER/GABI/GABI, S. 199 f. sowie die Kommentierung zu Art. 54 OR.

- 165 Vgl. zum diesbezüglichen Schweigen der Materialien die Botschaft des Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung zu einem Gesetzentwurf, enthaltend Schweizerisches Obligationen- und Handelsrecht, vom 27. November 1879, in: BBl 1880 I 149 ff., wo auf S. 187 zwar die Frage des «direkten» und «indirekten» Schadens angesprochen wird, sich zur Motivation zur Versorgerschadensregelung aber nichts finden lässt; ebenso unergiebig sind in dieser Frage: Bericht der ständeräthlichen Commission über den Entwurf eines schweizerischen Obligationen- und Handelsrechtes, vom 31. Mai 1880, in: BBl 1880 III 149 ff. (S. 162: Behandlung der unerlaubten Handlungen); Bericht der nationalräthlichen Commission über den Entwurf eines schweizerischen Obligationen- und Handelsrechtes, November 1880 (BBl 1881 I 153 ff.); Bericht des Bundesrathes an die Bundesversammlung, betreffend das Obligationenrecht, vom 28. Mai 1881 (BBl 1881 III 6 ff.); Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem Gesetzentwurf betreffend die Ergänzung des Entwurfes eines schweizerischen Zivilgesetzbuches durch Anfügung des Obligationenrechts und der Einführungsbestimmungen, vom 3. März 1905, in: BBl 1905 II 1 ff. (S. 14–17: Behandlung der unerlaubten Handlung).
- 166 Gl.M. sinngemäss MÖHRING, S. 78.
- 167 Gl.M. GELPKE, S. 48. – Zu der von der h.A. verlangten Widerrechtlichkeit in der Person des Getöteten vgl. hinten N 75.
- 168 GELPKE, S. 48.
- 169 So schon MOSER H., S. 41; gl.M. BK-BREHM, Vorbem. zu Art. 45 und 46 OR N 3, der aber trotz dieser Erkenntnis die Konsequenzen für die juristische Qualifizierung des Versorgerschadens nicht zieht.
- 170 Der Obligation, vgl. Erster Titel OR.
- 171 Gl.M. BK-BREHM, Vorbem. zu Art. 45 und 46 OR N 3; ebenso schon MOSER H., S. 41.
- 172 Z.B. im Solistenfall, vgl. N 51.
- 173 Vgl. zur Definition des sog. «Reflexschadens» vorne N 51. – Zur Notwendigkeit der Parallelität von Widerrechtlichkeit und Schaden als grundsätzliche Haftungsvoraussetzungen vgl. vorne N 66.
- 174 FREI A., S. 34; KELLER/GABI/GABI, S. 78 und 100; MARTI, S. 73; OFTINGER I, S. 230; ZK-OSER/SCHÖNENBERGER, Art. 45 OR N 8.
- 175 D.h. von den Voraussetzungen her.
- 176 Haftung des Schädigers nur für ein bestimmtes Mass.
- 177 Die Tatsache, dass bei den sog. «Reflexschäden» immer auch ein direkter Schaden (Erstscha den) vorliegt und dadurch eine Haftpflicht begründet wird, hätte eigentlich die Besonderheit des Versorgerschadens erkennen lassen müssen.
- 178 Fehlende eigene Widerrechtlichkeit und Existenz neben einem Schaden (Erstscha den) mit eigenem Verletzungstatbestand, weshalb dieser Erstscha den bereits ersatzrechtlich relevant ist.
- 179 Haftungsbegrenzend wirkt ja dann bereits die Voraussetzung, dass Schaden und Widerrechtlichkeit (bzw. allg. Verletzungstatbestand) in derselben Person kumuliert vorliegen müssen, vgl. vorne N 66.
- 180 Vgl. die Quellennachweise in Fn 174.
- 181 FISCHER, Schockschäden, S. 54. – Die Tatsache, dass den Versorgten ein eigenes Klagerecht eingeräumt wird, ändert nichts an dieser Feststellung und hat andere Gründe.
- 182 Und ein Widerspruch im Gesetz vermieden.
- 183 FISCHER, Schockschäden, S. 54 f.
- 184 Der immer im Verband mit einem ersatzfähigen Erstscha den steht, vgl. vorne N 59.
- 185 Der immer allein, also ohne Erstscha den, auftritt, vgl. vorne N 60.
- 186 Sinngemäss gl.M. einzig GELPKE, S. 48, der erklärt, Art. 45 Abs. 3 OR konstituiere nicht eine Ausnahme zu Art. 41 Abs. 1 OR, sondern bilde eine Ergänzung dieses Artikels für den Fall einer Tötung.

- 187 Sinn gemäss gl.M. HÜRZELER, S. 182 ff., der unter dem Blickwinkel anderer Aspekte zu ähnlichen Ergebnissen kommt: **(1)** Aus der blossen Existenz der Versorgerschadenregelung könne weder auf die Ersatzunwürdigkeit von Reflexschäden im Allgemeinen geschlossen werden, noch handle es sich um eine Sondernorm im Sinne einer ausnahmsweisen Ersatzfähigkeit eines Reflexschadens (S. 182). – **(2)** Die Funktion der (analogen) Regelung von § 1327 ABGB sei, den schadensrechtlichen Schutzbereich der Verhaltensnorm zu definieren, die Tötungen verbiete. Da der Schaden des Getöteten nicht fassbar und daher nicht sanktionierbar sei, sei es nur natürlich, jenen Schaden ausgleichen zu lassen, den die durch den Wegfall des Versorgers Geschädigten erlitten (S. 183). – **(3)** Insofern würden die (Dritt-)Geschädigten in den Schutzbereich einer schadensrechtlichen Normierung fallen, d.h. in den Schutzbereich von Art. 41 Abs. 1 OR (S. 183). – **(4)** Die durch den Regelungsbereich auch von Art. 45 Abs. 3 OR erfassten Personenkreise dürften deshalb nicht als blosse Reflexgeschädigte verstanden werden (S. 183). – **(5)** Hinsichtlich der analogen Bestimmung von § 844 BGB stehe in der deutschen Doktrin auch fest, dass sie (die Bestimmung) nicht in einem Regel-Ausnahme-Verhältnis stehe, da es ohne § 844 BGB an einem Anspruchsinhaber für die in § 823 Abs. 1 BGB angeordnete Ersatzpflicht im Falle der Tötung fehlen würde, weshalb die Norm entscheidend zur inneren Folgerichtigkeit der deliktsrechtlichen Gesamtregelung beitrage (S. 184). – **(6)** Der Regelungsgehalt von Art. 45 OR umfasse deshalb nicht mehr, als das allgemeine Haftpflichtrecht (gemeint ist Art. 41 Abs. 1 OR; der Verfasser) ohnehin gewähre. Die Tötung wirke somit als solche durch Verletzung des Rechtsgutes des menschlichen Lebens als Ausgangspunkt des ersatzfähigen Schadens, in casu Versorgerschaden (S. 184). – Insofern stimmt die These von HÜRZELER mit der hier vertretenen Bedeutung von Art. 45 Abs. 3 OR überein.
- 188 Vgl. statt vieler BK-BREHM, Art. 41 OR N 22b; KELLER/GABI/GABI, S. 77 («Die Begrenzung des Haftpflichtanspruches auf den Direktgeschädigten ist unerlässlich. Andernfalls hätte ein schädigendes Ereignis eine nicht abreisende Kette von Haftpflichtforderungen zur Folge»); OTTINGER I, S. 64, Fn 52 («Vielmehr ist darin eine unerlässliche Begrenzung der Interessen, die das Haftpflichtrecht schützen soll, zu sehen») m.w.V.
- 189 Zum Phänomen des Eintritts der (typischen) Schadensfolgen nur beim Dritten vgl. vorne N 60.
- 190 Gemeint sind sog. «Reflexschäden» (der Verfasser).
- 191 CANARIS, S. 157.
- 192 Vgl. statt vieler HAGEN, S. 1; REINHARDT, S. 9; VON TUHR/ESCHER, S. 111.
- 193 BGE 123 III 204, E. 2; CHK-FURRER/WEY, Art. 97/98 OR N 92; KELLER R., Drittschadensliquidation, S. 190 («allgemeines Prinzip des Schadenersatzrechts»); MARTI-SCHREIER, Rz 2; TANDOĞAN, S. 306; BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 40; vgl. auch vorne N 66.
- 194 HAGEN, S. 67.
- 195 HAGEN, S. 67 (Hervorhebung durch Verfasser).
- 196 Auch das Vertragsrecht verfügt in Art. 487 OR über eine Norm, die den Tatbestand des Auseinanderfallens der Anspruchsvoraussetzungen (einerseits Vertragsverletzung ohne Schaden, andererseits Schaden ohne Vertragsverletzung) regelt bzw. eine Drittschadensliquidation vorsieht (gl.M. u.a. KOLLER, recht 2013, S. 237; KUKO OR-MAURENBRECHER/SCHOTT, Art. 487 N 3 m.w.V.).
- 197 Sinn gemäss gl.M. bereits CANARIS, Lücken, S. 158. – gl.M. für die analoge Problematik im Vertragsrecht ARMBRÜSTER, FS Wiegand, S. 78–86; KUKO OR-THIER, Art. 97 N 29; BK-WEBER, Art. 97 OR N 300 ff. (insb. N 307).
- 198 CANARIS, Lücken, S. 158, Fn 58.
- 199 Sinn gemäss gl.M. zu § 823 BGB CANARIS, Lücken, S. 158, Fn 58.
- 200 Mit diesem Verständnis über Art. 41 Abs. 1 OR wird auch Art. 45 Abs. 3 OR auf die Funktion einer reinen Schadensberechnungsnorm, die die ersatzfähigen Nachteile aufzählt, beschränkt. Die Aktivlegitimation der Dritten (Versorgten) folgt schon aus Art. 41 Abs. 1 OR.
- 201 Zum Institut der sog. «Drittschadensliquidation» an sich vgl. MARTI-SCHREIER, Rz 1 ff. (313 ff.).
- 202 Zur gesetzlich anerkannten Drittschadensliquidation im Vertragsrecht vgl. Fn 196.